

Curso Examen de Grado
Módulo 1: Teoría de la Ley y Personas

Presentación.

El **examen de licenciatura** es uno de los obstáculos que los egresados de Derecho deben enfrentar para completar su proceso de titulación, definitivamente, es el más complejo de todos. El estudio enfrenta a los alumnos a páginas llenas de discusiones doctrinarias, plazos, conceptos, requisitos, características, distinciones, entre otros elementos, lo que provoca que los alumnos se sientan abrumados al tener la sensación que las materias de estudio son inabarcables. Estos hechos hacen necesario contar con ayuda para superar satisfactoriamente este proceso.

La *modalidad e-learning de preparación para el examen de grado* está destinada a aquellos alumnos que no pueden asistir a cursos presenciales en forma permanente, pero que requieren de la sistematización de la materia y la guía de un profesor (a) para su total estudio. Dicha modalidad se encuentra complementada con talleres presenciales de **derecho civil y procesal** que permiten el transversal y acabado estudio de diversas materias.

El curso se encuentra diseñado sobre la base del agrupamiento de las materias en distribuciones que siguen el siguiente esquema: Módulo, Unidad y Tema. Al finalizar cada módulo los alumnos deben rendir pruebas escritas a través de la plataforma e-learning.

Al término del curso cada alumno deberá rendir **Interrogaciones Orales**, las que son una aproximación real al momento de rendir el examen de grado y desde luego, hará que el alumno reafirme la visión de conjunto de las materias estudiadas.

Objetivo:

El curso busca preparar a los alumnos para rendir su examen de grado, mediante el repaso sistemático de los temas centrales del Derecho Civil y el desarrollo de competencias orales y retóricas para enfrentar dicho examen.

Al final del programa se espera que los alumnos:

1. Posean una visión sinóptica de todo el Derecho Civil y Procesal.
2. Relacionen las distintas instituciones del Derecho Civil y Procesal.
3. Adquieran competencias orales y retóricas para enfrentar el examen de grado.

El curso se articula en 11 módulos de contenidos, los que se indican a continuación

Módulos/Objetivo específicos:

Módulo 1: Teoría de la ley y Personas

En este módulo se analiza la principal fuente formal del Derecho, la ley. El alumno deberá aprender el concepto de ley, sus características y sus efectos, asimismo, el proceso de interpretación de la misma, todo lo anterior regulado en el Título Preliminar del Código Civil que es de aplicación general, no sólo para el Derecho Civil, sino que también para las otras ramas del Derecho.

Las personas constituyen los sujetos de derecho por antonomasia, todo el Derecho gira en torno a las personas, de ahí que sea de vital importancia conocer y aprender los tipos de personas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, como asimismo, el principio y fin de las mismas y sus atributos.

Las unidades que serán abordadas son las siguientes:

- Unidad 1: Teoría de la Ley.
- Unidad 2: Personas Naturales y Jurídicas.

Módulo 2: Teoría del Acto Jurídico

La Teoría del Acto Jurídico constituye la base fundamental de todo el Derecho Civil Patrimonial, no se vislumbra un acto o contrato, sin una manifestación de voluntad, pero éste además debe cumplir con otros requisitos, debe tener causa, objeto y a veces el legislador exige formalidades especiales, las solemnidades.

El alumno deberá conocer la clasificación de los actos jurídicos, sus elementos, requisitos de existencia y de validez. Debe ser capaz de discernir cuando la voluntad está viciada, como cuando el Objeto o la Causa del acto jurídico sean ilícitas.

Se estudiará además, la principal sanción de ineficacia que contempla el Código Civil, la nulidad, instituto que es transversal a toda la legislación civil, por ello el alumno debe conocer sus causales, titulares y efectos, tanto entre las partes como respecto de terceros.

Los contenidos se articulan en las siguientes unidades:

- Unidad 1: Teoría del Acto Jurídico.
- Unidad 2: La Voluntad Jurídica.
- Unidad 3: La Voluntad en los Actos Jurídicos.
- Unidad 4: Los Vicios de la Voluntad.
- Unidad 5: El Objeto.
- Unidad 6: La Causa.
- Unidad 7: Las Formalidades.
- Unidad 8: Efectos de los Actos Jurídicos.
- Unidad 9: Ineficacia de los Actos Jurídicos.
- Unidad 10: La Representación en los Actos Jurídicos.

Módulo 3: Derecho de Bienes

Los alumnos conocerán la regulación del Código Civil relativa los bienes, los modos de adquirir, así como las limitaciones al dominio y las acciones destinadas a proteger el dominio y la posesión. Los alumnos deben ser capaces de conceptualizar los distintos tipos de bienes y derechos reales; comprender la regulación del dominio en el sistema nacional, como de los modos de adquirir la propiedad y demás derechos reales limitados; comprender, distinguir y aplicar las instituciones de mera tenencia, posesión y dominio, dando énfasis en sus relaciones y diferencias.

Los contenidos se presentan a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: De los Bienes.
- Unidad 2: De la Propiedad.
- Unidad 3: De la Tradición.
- Unidad 4: De la Posesión.
- Unidad 5: De la Prescripción Adquisitiva.
- Unidad 6: De las Limitaciones al Dominio.
- Unidad 7: De la Acción Reivindicatoria.

Módulo 4: Las Obligaciones

En este módulo se analiza el vínculo obligacional, independiente de la fuente que lo ha creado. Los alumnos deben conocer el concepto de obligación y sus elementos. Se estudiarán las distintas clasificaciones de las obligaciones, como también sus efectos, y lo qué ocurre en caso de su incumplimiento, analizando cada una de las posibilidades que tiene el acreedor. Finalmente se estudiarán los modos de extinguir las obligaciones, y el principal de todos, el pago, que es el efecto normal de las obligaciones.

Al final del módulo los alumnos deberán: a) conocer el concepto de obligación (derecho personal) y sus diferencias con los derechos reales; b) conocer las distintas clasificaciones de las obligaciones; c) comprender los efectos de las obligaciones, y las consecuencias del incumplimiento de las mismas; d) conocer, comprender e identificar cada uno de los modos de extinguir las obligaciones.

Los contenidos se presentan a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: Conceptos Generales.
- Unidad 2: Fuentes de las Obligaciones.
- Unidad 3: Clasificación de las Obligaciones.
- Unidad 4: Obligaciones Condicionales.
- Unidad 5: Efectos de las Obligaciones.
- Unidad 6: De la Evaluación de los Perjuicios.
- Unidad 7: Derechos Auxiliares del Acreedor.
- Unidad 8: De los Modos de Extinguir las Obligaciones.

Módulo 5: Fuentes de las Obligaciones.

Las fuentes de las obligaciones dicen relación con el nacimiento de las mismas. Se analiza pormenorizadamente la principal de todas, los contratos, como también la responsabilidad extracontractual derivada de los delitos y cuasidelitos.

Al final del módulo los alumnos deberán: a) entender y comprender el concepto de contrato, las clasificaciones legales y doctrinarias y los principios que los rigen; b) conocer y entender los distintos tipos de contratos que regula el Código Civil, específicamente los contratos consensuales, solemnes y de garantía, en cada uno de ellos los alumnos deberán saber su concepto, características y efectos; c) finalmente, se analiza la responsabilidad extracontractual emanada de los delitos y cuasidelitos, donde los alumnos deberán entender, comprender y aplicar las consecuencias jurídicas de la comisión de un ilícito civil, como también el sistema de responsabilidad que rige en nuestra legislación

Los contenidos se presentan a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: Teoría General del Contrato.
- Unidad 2: Los Contrato en Particular. Contratos Consensuales y Solemnes.
- Unidad 3: Contratos Accesorios o de Garantía.
- Unidad 4: Interpretación de los Contratos.
- Unidad 5: Responsabilidad Civil Extracontractual.

Módulo 6: Derecho de Familia

Al igual que en el Derecho de Familia, en el Derecho Sucesorio la autonomía de la voluntad se encuentra restringida, existiendo una mínima libertad para testar, ya que el legislador, siguiendo el orden natural de los afectos, establece quiénes podrán suceder al causante, tanto en la sucesión testada mediante la figura de las asignaciones forzosas, como en la intestada mediante los órdenes de sucesión.

Al final del módulo se espera que los alumnos conozcan, entiendan y den aplicación a los conceptos de sucesión por causa de muerte y derecho real de herencia; deberán conocer y aplicar las reglas de capacidad y dignidad para suceder, los tipos de sucesión existentes (testada e intestada), saber cuáles son los órdenes de sucesión y las modalidades que pueden afectar a las asignaciones. Asimismo, deberán conocer y aplicar las medidas de protección que se han establecido para proteger las asignaciones forzosas mediante acciones y la formación de los acervos imaginarios.

Los contenidos se presentan a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: Nociones Generales.
- Unidad 2: El Matrimonio.

- Unidad 3: Separación de los Cónyuges.
- Unidad 4: Extinción del Matrimonio.
- Unidad 5: Efectos del Matrimonio.
- Unidad 6: Regímenes Matrimoniales.
- Unidad 7: Los Bienes Familiares.
- Unidad 8: Filiación.
- Unidad 9: El Estado Civil.
- Unidad 10: Derecho de Alimentos

Módulo 7: Derecho Sucesorio

Al igual que en el Derecho de Familia, en el Derecho Sucesorio la autonomía de la voluntad se encuentra restringida, existiendo una mínima libertad para testar, ya que el legislador, siguiendo el orden natural de los afectos, establece quiénes podrán suceder al causante, tanto en la sucesión testada mediante la figura de las asignaciones forzosas, como en la intestada mediante los órdenes de sucesión.

Al final del módulo se espera que los alumnos conozcan, entiendan y den aplicación a los conceptos de sucesión por causa de muerte y derecho real de herencia; deberán conocer y aplicar las reglas de capacidad y dignidad para suceder, los tipos de sucesión existentes (testada e intestada), saber cuáles son los órdenes de sucesión y las modalidades que pueden afectar a las asignaciones. Asimismo, deberán conocer y aplicar las medidas de protección que se han establecido para proteger las asignaciones forzosas mediante acciones y la formación de los acervos imaginarios.

Módulo 8: Derecho Procesal Orgánico y Disposiciones Comunes

Este módulo consta de dos grandes materias, en primer lugar, Derecho Procesal Orgánico que básicamente consiste en el estudio de la Jurisdicción y la Competencia ambos reglamentados en el Código Orgánico de Tribunales, y en segundo lugar, Disposiciones Comunes a todo Procedimiento regulada en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, que como su nombre lo indica son aplicables a todos los procedimientos regulados en este cuerpo legal como en leyes especiales.

En relación al Derecho Procesal Orgánico los alumnos deberán conocer y aplicar las reglas de competencia y las clasificaciones de la misma, lo que tiene importancia práctica al momento de deducir una demanda. En cuanto a la Jurisdicción se espera que los estudiantes conozcan su concepto, características y diferencias con la Competencia.

En materia de Disposiciones Comunes los alumnos deberán conocer los distintos tipos de resoluciones judiciales que existen, sus requisitos y efectos; los tipos de notificación y el campo de aplicación de cada una de ellas; deberán manejar los conceptos de patrocinio y mandato judicial,

institutos que si bien normalmente van de la mano, son distintos entre sí. Finalmente el estudio de esta materia implica conocer y manejar el concepto de proceso, como medio de solución de conflictos, sus elementos y sus intervinientes, tribunal, partes y terceros.

Módulo 9: Los Procedimientos

Los procedimientos abarca principalmente el estudio del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía y del Juicio Ejecutivo por Obligación de Dar, regulados en los Libros II y III del Código de Procedimiento Civil, ambos piedras angulares del Derecho Procesal por su aplicación subsidiaria. Sin embargo, este módulo también abarca las medidas prejudiciales, los incidentes y los medios de prueba en particular.

Al final del módulo se espera que los alumnos conozcan cada uno de los procedimientos que se estudiarán, pudiendo ser capaces de discernir su ámbito de aplicación y sus diversas etapas, como las reacciones o defensas de las partes litigantes, en especial del demandado y las consecuencias de sus posibles actitudes. En cuanto a las medidas prejudiciales el alumno deberá conocerlas detalladamente, en especial su finalidad, para que al momento de preparar la entrada al juicio interponga la adecuada.

También deberán conocer cada uno de los medios de probatorios, su oportunidad procesal y su valor probatorio.

Módulo 10: Recursos Procesales Civiles

Los recursos procesales civiles se enmarcan dentro de la etapa que podemos denominar de impugnación de las resoluciones judiciales y su estudio abarca la mayoría de los recursos que establece el legislador civil, desde los recursos más simples a los más complejos, desde los recursos de enmienda a los de nulidad.

El principal recurso es el de apelación, por cuanto concretiza el principio de la doble instancia y además muchos de sus trámites se aplican de forma subsidiaria los demás recursos, en especial a los recursos de casación.

Al final del módulo los alumnos deberán saber los conceptos de cada uno de los recursos, las resoluciones recurribles, los plazos de interposición, su tramitación tanto a nivel del tribunal a quo como del ad quem, y la naturaleza jurídica de la resolución judicial que los resuelve, sea acogiéndolos o rechazándolos.

Módulo 11: Procedimiento Penal

El proceso penal conlleva el estudio de sus principios inspiradores, sus intervinientes, los diferentes procedimientos establecidos en la ley y los recursos que proceden en contra de las resoluciones judiciales.

El alumno deberá conocer los principios que lo envuelven y su aplicación al caso concreto, también deberá conocer el ámbito de aplicación de cada uno de los procedimientos, distinguiendo entre cada una de sus etapas, como también los derechos de los intervinientes. En cuanto a los recursos penales deberá saber sus conceptos, las resoluciones recurribles, los plazos de interposición, su tramitación y la naturaleza jurídica de la resolución judicial que los resuelve, sea acogiendo o rechazando.

Durante el desarrollo del módulo, los y las participantes dispondrán de los contenidos a través del sitio del curso. Accederán a recursos como PDF, sitios de interés, multimedios y bibliografía relacionada con los contenidos, así como también se propone la realización de actividades de evaluación para medir sus progresos.

Las consultas sobre contenidos, serán canalizadas a través del correo electrónico y el Foro de Debate.

Bien, iniciemos ahora nuestro aprendizaje, revisando los contenidos del módulo 1.

Unidad 1: Teoría de la Ley

Tema 1: La Costumbre como fuente del derecho.



La costumbre es una norma jurídica de generación espontánea. Se le define como “La observancia constante y uniforme de una regla de conducta, realizada por la generalidad o gran mayoría de los miembros de una comunidad social, de manera constante y uniforme y con la convicción de que responde a una necesidad jurídica”.

Los elementos de la costumbre son dos:

- a) **Uno externo, material u objetivo**, que estriba en la general, constante y uniforme repetición de actos similares y, por lo tanto, se requiere que no exista otra norma de conducta contraria o inversa, porque de otra manera perdería su característica de generalidad. La práctica debe prolongarse en el tiempo, como expresión de un acuerdo colectivo. Además debe ser pública, esto es, conocida por la sociedad y sus autoridades.
- b) El segundo **elemento es interno, espiritual o subjetivo**, y está fundado en la convicción, por parte de los miembros de la comunidad, de la necesidad jurídica de aquella regla y, por ende, de su obligatoriedad.

La costumbre no debe ser confundida con los usos, que tan sólo son prácticas o conductas que por conveniencia, oportunidad u otros motivos, siguen en sus relaciones jurídicas determinados sujetos. No tienen el carácter de generalidad de la costumbre, ni tampoco son realizados con la convicción de estar cumpliendo con un imperativo jurídico. Por lo tanto, el uso nunca constituye derecho, aunque pueda servir de base o de germen de una futura costumbre.

La costumbre, según sea el punto de vista que se considere, admite diversas clasificaciones:

a) **Costumbre general y local.**

Tomando como base el factor territorial en que impera, la costumbre puede ser general, la que rige en todo el territorio de un Estado, y local, la que se observa en una determinada parte del territorio del Estado.

b) Costumbre nacional y extranjera.

De acuerdo con el país en que se practique, la costumbre es nacional o extranjera.

c) Costumbre contra la ley, fuera de la ley y según la ley.

Según sea su relación con la ley, la costumbre es contra la ley, fuera de la ley o según la ley.

Costumbre contra la ley (contra legem) es la que introduce una norma destructora de la ley antigua, ya sea proclamando su inobservancia, ya sea imponiendo una conducta diferente de la establecida por la ley. En cualquiera de estas dos formas conduce al desuso de la norma legislativa.

Costumbre fuera de la ley (praeter legem) es la que rige una materia o asunto sobre el cual no hay normas legislativas.

Costumbre según la ley (secundum legem) es la que adquiere el carácter de norma jurídica en razón de ser llamada por la ley a regir un asunto dado. Nuestro Código Civil (en adelante “CC”) reconoce la costumbre según la ley al decir que “la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella” (artículo 2). Que la costumbre no constituye derecho significa que no tiene fuerza de ley, porque en esta acepción está tomada la palabra derecho; pero, de acuerdo con la última parte de la disposición transcrita, la costumbre adquiere fuerza de ley cuando ésta se remite a aquella.

La consideración de la norma consuetudinaria se explica porque la legislación por más general o casuística que sea, no puede llegar a comprender todas las modalidades que adoptan las relaciones de los hombres. Numerosos son los casos en que se prefiere expresamente la costumbre. Por ejemplo, el CC declara que si nada se ha estipulado sobre el tiempo de pago del arrendamiento de predios rústicos, se observará la costumbre del departamento (artículo 1986). Según el artículo 2117 del CC la remuneración del mandatario se determina por la convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre o el juez. Muy importante es la referencia que hace a la costumbre el artículo 1546 del CC al consagrar que los contratos deben ejecutarse de buena fe, obligando no sólo a lo que en ellos se expresa sino que a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.

El **Código de Comercio** (en adelante “CCO”) acepta la costumbre fuera de la ley, al decir que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando concurren los requisitos que señala el artículo 4. Además su artículo 6 señala que “Las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones mercantiles”.

La costumbre tiene notable importancia en el Derecho Internacional Público, ya que constituye su fuente principal. Por el contrario, en el Derecho Penal la costumbre carece de toda fuerza pues no hay delito ni pena sin una ley previa que lo establezca.

A pesar que la costumbre en los casos en que la ley la llama a regir es una norma jurídica, necesita ser probada ante los Tribunales de Justicia porque, al revés de lo que ocurre con la ley, ninguna autoridad pública atestigua oficialmente su existencia. En materia civil cualquier medio idóneo para demostrar la costumbre es aceptable: instrumentos públicos o privados, testigos, etc. No ocurre lo mismo en materia comercial en que reina un criterio restrictivo.

Las diferencias entre la costumbre civil y la mercantil son las siguientes:

- a) La costumbre mercantil entra a regir en el silencio de la ley; la civil sólo cuando la ley se remite expresamente a ella.
- b) El CC no determina los requisitos que debe reunir la costumbre para que sea fuente del derecho; pero sí el CCO al señalar “Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que la constituyen son uniformes, públicos y generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los Juzgados de Comercio.
- c) El CC no especifica los medios por los cuales debe probarse la costumbre, de modo que es posible emplear todos los medios que el derecho establece. El CCO, en cambio, señala taxativamente los medios de prueba de la existencia de la costumbre, la cual “sólo podrá ser probada por alguno de estos medios: 1° por un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella; 2° por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba “ (artículo 5)

Tema 2: Interpretación de la Ley.

La interpretación de la ley consiste en fijar su verdadero sentido y alcance.

La interpretación se realiza, no arbitrariamente, según puro arbitrio o sentimiento del que la hace, sino obedeciendo a ciertos criterios o principios directrices. Cuando estos criterios o principios los señala el legislador, el sistema de interpretación se denomina reglado; de lo contrario, no reglado. El CC consagra el primer sistema.

El sistema reglado de interpretación está, entre nosotros, en el título preliminar del CC y ordinariamente se han considerado como normas universales, no exclusivas del derecho privado ni específicamente del civil.

2.1 Clases de interpretación:

a) Interpretación doctrinal o privada y de autoridad o pública.

Atiende a la persona, institución u órgano de quien emane la interpretación. La interpretación de autoridad obliga con mayor o menor amplitud; la particular no obliga. La interpretación de autoridad se divide en judicial, legal o administrativa. El artículo 3 del Código Civil marca la extensión obligatoria de la interpretación legal o auténtica y la de la judicial: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de la causas en que actualmente se pronunciaren”. La interpretación legal se llama también interpretación auténtica por provenir del mismo órgano que dictó la ley interpretada. Las interpretaciones de los órganos administrativos no obligan a los Tribunales de Justicia. Los elementos que constituyen la interpretación realizada por el juez y que, a su vez representan los medios de que el intérprete se sirve son sustancialmente cuatro: gramatical, lógico, histórico y sistemático.

b) Interpretación declarativa, restrictiva y extensiva.

Atiende al resultado a que conduzca la interpretación. Si el proceso interpretativo consiste en la investigación de la voluntad de la ley expresada en una fórmula, que puede ser inadecuada, el resultado de la investigación será necesariamente reconocer que la fórmula o términos literales coinciden exactamente con el pensamiento legislativo, es decir, que lo exterioriza con fidelidad y acierto (interpretación declarativa); comprobar que expresan menos de los que fue querido (interpretación restrictiva); o comprobar que expresan más (interpretación extensiva).

La interpretación judicial es la que desarrollan los Tribunales de Justicia en sus sentencias. Su fuerza obligatoria es muy limitada ya que sólo alcanza a las partes litigantes de acuerdo al artículo 3 inciso 2 del CC. Las excepciones que amplían la fuerza obligatoria de las sentencias a todo el mundo son las que en cada caso expresamente señala la ley, como por ejemplo, el fallo judicial que declara verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo. La interpretación judicial no obliga ni siquiera al mismo juez que falla el conflicto en que hizo la interpretación pues puede el mismo juez, en casos análogos, interpretar la ley y resolver los otros juicios en forma diversa.

2.2 Elementos de interpretación

El CC da a los jueces una serie de normas esenciales para la interpretación de las leyes, en sus artículos 19 a 24. El CC considera varios elementos de interpretación:

a) Elemento gramatical.

“Cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” (artículo 19 inciso 1).

Es claro el sentido de la ley cuando los términos que emplea no son oscuros y cuando, al mismo tiempo, son cabales y no son ambiguos o inequívocos porque aparecen usados en un significado que no admite dudas y porque comprenden exactamente, ni más ni menos, lo que la ley quiso regular.

Dada la importancia que tiene el significado de las palabras en la interpretación, el CC precisa que “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal” (artículo 20).

De esta disposición resulta que tratándose de palabras no definidas expresamente por el legislador, las demás (siempre que no sean técnicas) el legislador las emplea en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Cuando la ley emplea las palabras técnicas de una ciencia o arte, estas deben tomarse en el sentido que les dan los que profesan la misma ciencia o arte, salvo que aparezcan claramente que se han tomado en sentido diverso (artículo 21). Un ejemplo de una palabra técnica que debe tenerse por usada en su sentido común, se da cuando el CC se refiere a los dementes, que hoy deben ser considerados enfermos mentales.

b) Elemento histórico.

La historia fidedigna de la ley sirve para recurrir a la intención o espíritu de aquella a fin de determinar su sentido (artículo 19, inciso 2). La historia fidedigna de la ley la constituyen las circunstancias existentes a la época de elaborarse el proyecto de ella, el texto de ese proyecto enviado al Congreso Nacional, el Mensaje del Ejecutivo que lo acompaña, las actas de las Comisiones Parlamentarias que examinan e informan el proyecto, las explicaciones y discusiones habidas en ambas Cámaras hasta su aprobación.

c) Elemento lógico.

Consiste en la concordancia que debe existir entre las diversas partes de la ley, pues es natural que éstas no sean contradictorias y exista entre ellas una unidad conceptual y de criterio. Las expresiones oscuras pueden aclararse determinando la intención o espíritu de la ley claramente manifestado en ella misma (artículo 19 inciso 2).

Otra pauta del elemento lógico que contribuye a precisar la voluntad de la ley es la regla del contexto, o sea, el conjunto del texto que rodea una frase citada y del que depende la verdadera significación de ésta. El CC dispone que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (artículo 22). Esta norma se funda en que todas las partes de una ley forman una unidad y responden a una misma intención o espíritu y es natural entonces que guarden armonía y no contradicción.

d) Elemento sistemático.

En el elemento sistemático la correspondencia de la ley se busca más allá de la propia ley interpretada: “Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto” (artículo 22 inciso 2)

e) Espíritu general de la legislación y equidad natural.

“En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural” (artículo 24).

El espíritu general de la legislación es el principio o idea central de toda ella o de todas las normas que integran cada institución, por ejemplo, amplias garantías a los intereses de los menores de edad, facilitar la circulación de los bienes y capitales, etc. La equidad es el sentimiento seguro y espontáneo de lo justo y lo injusto que deriva de la sola naturaleza humana con prescindencia del derecho positivo.

En la interpretación de la ley, debe tenerse asimismo en consideración el principio de la especialidad consagrado en los artículos 4 y 13. Este principio consiste en hacer prevalecer las leyes especiales sobre las generales y su fundamento estriba en el pensamiento de que si el legislador dicta una ley sobre una determinada materia es porque desea sustraerla o exceptuarla de la regulación de la ley general. El artículo 4 dispone que las disposiciones contenidas en los otros Códigos y leyes especiales de la República deben aplicarse con preferencia a las del CC. El artículo 13 alude a las disposiciones de un mismo cuerpo legal, señalando que las disposiciones de una ley relativas a cosas o negocios particulares prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley cuando entre unas y otras hubiere oposición.

También debe tenerse presente la disposición consagrada en el artículo 23: “Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes”.

Debe remarcarse que las normas de interpretación de la ley no son meros consejos dados al juez sino criterios obligatorios que debe seguir para desentrañar la voluntad de la ley.

Otra clase de interpretación de autoridad pública u oficial es la interpretación legal o auténtica. Esta es la que hace una ley de otra anterior cuyo sentido es oscuro, ambiguo o controvertible, la ley interpretativa viene a fijar el verdadero, genuino o auténtico sentido de la ley interpretada. A diferencia de la interpretación judicial que solo obliga a las partes del juicio en que el Tribunal de Justicia hizo su pronunciamiento, la interpretación del legislador obliga a toda la sociedad (artículo 3 inciso 1). La ley interpretativa se entiende incorporada en la interpretada (artículo 9 inciso 2). Por lo tanto, los efectos obligatorios de la ley interpretativa rigen no desde su fecha sino desde el día que entró en vigencia la ley interpretada. O sea, la ley interpretativa es en realidad retroactiva, porque sus efectos alcanzan a situaciones o relaciones jurídicas surgidas antes de su entrada en

vigor. Eso sí, las leyes interpretativas no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio entre la vigencia de la ley interpretada y la interpretativa (artículo 9 inciso 2).

2.3 Aforismos jurídicos

Aparte de los preceptos del CC se emplean en la interpretación de las leyes diversos aforismos jurídicos formados en la práctica del foro universal y que a menudo hacen uso de ellos la doctrina y la jurisprudencia. Ninguno de ellos es concluyente o de valor absoluto y ninguno debe ser empleado de modo exclusivo:

a) **Argumento de analogía o a pari.**

Se expresa en el adagio “Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”. La analogía es un razonamiento que nos lleva a concluir que un caso no previsto por la ley, ni en su letra ni en su espíritu, se resuelve conforme a otro semejante o análogo previsto por ella, o lo mismo para un caso previsto pero cuya ley aplicable no tiene un sentido claro a su respecto. En el primer extremo, el del caso no previsto por la ley, estamos en presencia de un vacío o laguna de la misma, y la analogía es un medio de integración del derecho; en el segundo de interpretación. El uso de la analogía como medio interpretativo se da respecto de las leyes oscuras o ambiguas. El CC contempla la analogía como medio interpretativo al disponer que los “Pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados (es decir, aclarados) por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto” (artículo 22 inciso 2). Hay casos en que expresamente se prohíbe recurrir a la analogía, pero aun sin tal prohibición se entiende universalmente que no pueden aplicarse por analogía las leyes excepcionales, las que establecen sanciones y las que restringen el ejercicio de los derechos.

b) **Argumentación de contradicción o a contrario sensu.**

Parte de la voluntad expresada en el caso previsto por el legislador para suponerle en todos los otros casos una voluntad contraria. Ordinariamente se expresa en las siguientes frases: “Incluida una cosa se entienden excluidas las demás” y “Quien dice lo uno niega lo otro”.

c) **Argumento a fortiori.**

En su virtud se extiende la disposición de la ley a un caso no previsto por ella, pero en el cual concurren razones más poderosas para aplicarla que en el mismo caso previsto. Se sintetiza en las siguientes frases: “Quien puede lo más puede lo menos” y “Al que le está prohibido lo menos con mayor razón le está prohibido lo más”.

d) **Argumento de no distinción.**

Se expresa en el siguiente adagio: “Donde la ley no distingue tampoco nosotros tenemos que distinguir”.

e) El absurdo.

Debe rechazarse toda interpretación que conduzca al absurdo, esto es, cualquiera conclusión contraria a las leyes de la lógica, del buen sentido o de la razón.

Por muy acucioso que sea el legislador, no puede prever absolutamente todos los casos que la realidad social actual presenta y menos los que pueden surgir en el futuro a consecuencia de las transformaciones técnicas, sociales, económicas que suceden con mayor o menor rapidez en la vida de los pueblos. En estos casos en que no hay ley aplicable, ni clara ni oscura, no se está frente a un problema solucionable con la interpretación de la ley, sino con la integración de la misma que tiende a llenar sus vacíos o lagunas.

Lagunas o vacíos de ley son los casos o situaciones que no encuentran una norma específicamente adecuada para ser resuelta por ella. Si esos casos no pueden ser resueltos ni aún por todo el ordenamiento jurídico considerado en su conjunto se habla de lagunas de derecho. Se discute la existencia de lagunas de derecho. La doctrina dominante estima que sólo pueden existir lagunas de ley y no de derecho porque cualquier caso que se presente puede ser resuelto de acuerdo a las orientaciones marcadas por el derecho mismo; las lagunas formales pueden ser llenadas con el espíritu general de la legislación.

Nuestro derecho positivo prevé las lagunas de la ley. Al respecto dispone que reclamada la intervención de los Tribunales de Justicia en forma legal y en negocios de su competencia, no pueden excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión, de acuerdo al artículo 10 inciso 2 del Código Orgánico de Tribunales (en adelante "COT"). Es el llamado principio de inexcusabilidad de los tribunales.

Nuestra legislación contempla en forma expresa la equidad como medio de llenar las lagunas de la ley, pues dice que en defecto de las leyes las sentencias definitivas deben contener los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. En tal sentido el artículo 170 número 5 del Código de Procedimiento Civil (en adelante "CPC").

También se podría recurrir, para colmar la laguna, al artículo 24 del CC, que si bien se refiere a la interpretación de la ley y no al caso de lagunas legales, es claro que el juez también podrá apoyarse en el espíritu general de la legislación y en la equidad natural para solucionar un caso que no tiene ley aplicable, porque si ello le está permitido cuando la ley es oscura y contradictoria, con mayor razón le estará permitido cuando no hay ley.



Tema 3: Efectos de la Ley.

El campo normal de aplicación de normas jurídicas lo determina, por una parte, **el territorio sobre el cual impera la autoridad soberana que las dicta**; por otro, **el tiempo que media en que la ley comienza a regir y aquel en que cesa su fuerza**

obligatoria. El tiempo y el espacio son los límites naturales de la eficacia de las leyes, pero, como se verá más adelante, no son límites absolutos.

3.1 Efectos de la Ley en el Tiempo.

Por regla general las leyes son dictadas para que subsistan por un tiempo indefinido, pero no eterno, porque las necesidades sociales a las que tiende satisfacer o desaparecen o cambian o surgen otras nuevas, y entonces las respectivas leyes deben perder su eficacia definitivamente o ser modificadas, en fin, dar paso a otras leyes que llenen mejor las mismas necesidades o que satisfagan las nuevas que el progreso de la civilización ha hecho surgir.

El ciclo de existencia de las leyes comienza desde su publicación en el Diario Oficial (en adelante “DO”) o desde el día que ellas mismas fijan, y pierden su eficacia, es decir, su obligatoriedad, a partir de la fecha en que se produce una causa que determina tal pérdida. La causa que priva de existencia a las leyes puede ser respecto de ellas extrínseca o intrínseca: la primera, la externa está constituida por la derogación y la segunda, la interna, por cumplirse el término preestablecido para su duración o el logro del fin perseguido por la ley.

3.1.1 El Principio de la Irretroactividad.

Cuando entra a regir una nueva ley, el principio es que ella no se aplica a situaciones anteriores a su vigencia y que corresponden al imperio de la ley antigua. Al respecto el CC señala: **“La ley puede sólo disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo”** (artículo 9 inciso 1).

Este principio de la irretroactividad de la ley, obligatorio para el juez, suscita dificultades en su aplicación respecto de hechos y actos jurídicos que empiezan a formarse bajo la vigencia de una ley y terminan de consumarse o perfeccionarse bajo el vigor de una nueva ley; también se presentan dificultades cuando los efectos de un hecho o acto jurídico nacido bajo el imperio de una ley se despliegan bajo el dominio de otra. En estos casos es necesario determinar el campo de aplicación de la ley antigua y el de la nueva de modo que esta última no tenga efecto retroactivo si expresamente no se lo ha dado el legislador.

El principio de la irretroactividad de las leyes se fundamenta en la seguridad jurídica. Los derechos permanecerían inciertos si después de haberse adquirido conforme a una ley, pudieran ser frustrados por otra que exigiera nuevos supuestos o requisitos para tenerlos por definitivamente consolidados.

Como el principio de la irretroactividad está consagrado en el CC, es decir, en una ley ordinaria y no en una constitucional, no compromete al legislador ya que este solo se encuentra subordinado a la Carta Fundamental. Excepcionalmente dicha Carta, directa o indirectamente, impide al legislador dictar normas retroactivas:

- a) Así ocurre en materia penal pues, al respecto, la Constitución dispone en su artículo 19 número 3 que “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale la ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”.
- b) En materia civil hay una prohibición indirecta de dictar leyes retroactivas que traigan como consecuencia la vulneración del derecho de propiedad en sus diversas especies: nadie, en caso alguno, puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de sus atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador, teniendo el expropiado siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado (artículo 19 número 24). Por tanto, la circunstancia de que sea inconstitucional una ley que atente contra el derecho de dominio o de propiedad constituido regularmente bajo el imperio de otra, determina que el legislador no pueda dictar leyes retroactivas con respecto a ese derecho.

En resumen, el legislador es libre para dictar leyes retroactivas, pero excepcionalmente, no puede hacerlo en materia penal cuando desfavorece al reo y tampoco en materia civil, cuando la retroactividad importa un atentado contra el derecho de propiedad.

El CC al disponer que la ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo (artículo 9 inciso 1) establece una norma obligatoria para el juez, el cual no puede aplicar una ley con efecto retroactivo si ella misma no lo señala expresamente. El juez no debe darle a la ley una inteligencia que lo conduzca a la aplicación de ella con efecto retroactivo.

Si la norma general es que la ley no tenga efecto retroactivo, la excepción, la retroactividad de la ley, lógico es que se declare expresamente y que su interpretación y aplicación sean restrictivas, de derecho estricto.

Con respecto a la retroactividad de las leyes interpretativas, el CC señala en su artículo 9 inciso 2:

“Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas a éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio”.

Dado que las leyes interpretativas jurídicamente no contienen innovación alguna, se entienden incorporadas a las leyes que interpretan y rigen a partir de la fecha de éstas. Una ley se reconoce como interpretativa si presenta las siguientes dos características que le son inherentes:

- a) El contener la mera fijación del sentido incierto o dudoso de una de una ley anterior, y
- b) El encerrar una solución que habría podido adoptar la jurisprudencia, pues en este acto, el legislador se transforma, por un momento, en un simple intérprete del derecho, a la manera del juez.

Muchas veces el legislador dicta las llamadas disposiciones transitorias, mediante las cuales previene los conflictos entre la ley antigua y la nueva, al determinar los efectos precisos que ésta debe producir en las relaciones o situaciones anteriores. Antes de aplicar la ley sobre efecto retroactivo de las leyes es preciso ver si existen en una nueva ley estas disposiciones transitorias y sólo si no existen o si las que hay presentan vacíos, se aplican las normas de la ley de efectos retroactivos.

Han surgido principalmente dos teorías acerca de la determinación del efecto retroactivo de las leyes. Se parte de la base que si una ley no declara expresamente que debe aplicarse con efecto retroactivo, impera el principio general de la irretroactividad, y el juez ha de aplicarla cuidando de no darle efecto retroactivo. Si la nueva ley no contiene disposiciones transitorias que se encarguen de dar luz acerca de su relación con las normas existentes, corresponde al juez señalar los límites de las nuevas normas con respecto a los hechos, actos o situaciones generados con anterioridad a su vigencia. Las teorías procuran servirle de guía en tal determinación:

a) Teoría clásica de los derechos adquiridos y las meras expectativas.

Una ley será retroactiva cuando lesione intereses que para su titulares constituyen derechos adquiridos en virtud de la ley antigua; pero no lo es cuando sólo vulnera meras facultades legales o simples expectativas.

Se entiende por derecho adquirido *todo derecho que es consecuencia de un hecho apto para producirlo bajo la ley vigente en el hecho se ha realizado y que el derecho ha entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, sin que importe la circunstancia de que la ocasión de hacerlo valer se presente en el tiempo en que impera otra ley.*

Las simples expectativas son las esperanzas de adquisición de un derecho fundado en la ley vigente y aun no convertida en derecho por falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley.

La ley nueva no puede lesionar, si el legislador no le ha dado efecto retroactivo, los derechos adquiridos; pero sí puede vulnerar las facultades legales y las simples o meras expectativas, porque aquellas ni éstas constituyen derechos que hayan entrado definitivamente a formar parte del patrimonio de una persona.

La teoría de los derechos adquiridos, entre otras dificultades que presenta en la práctica, resalta la de no ser siempre posible distinguir cuando se está frente a un verdadero derecho adquirido o ante una expectativa.

b) Teoría moderna de Roubier.

Reposa sobre la distinción entre efecto retroactivo, **que es la aplicación de la ley en el pasado, en el tiempo anterior a su entrada en vigor, y efecto inmediato, que es su aplicación en el presente.**

La teoría de Roubier parte de la observación de que toda situación jurídica puede ser sorprendida por la ley en diversos momentos, a saber, el de su constitución, el de producción de sus efectos o en el de su extinción.

La ley nueva tiene efecto retroactivo si ataca a las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas o a los elementos ya existentes que forman parte de la constitución o de la extinción de una situación jurídica en vías de constituirse o extinguirse.

Por el contrario, la ley nueva sólo produce efecto inmediato si rige, desde su entrada en vigor, los efectos de las situaciones jurídicas anteriormente establecidas, así como su extinción y la constitución de situaciones jurídicas nuevas.

El efecto inmediato es la regla pero hay que considerar una excepción muy importante, pues el efecto inmediato no afecta a los contratos, los cuales constituyen por su esencia instrumentos de variedad jurídica.

3.1.2 Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.

Se dictó el 7 de octubre de 1861. Se inspira, en general, en la teoría de los derechos adquiridos y de las meras expectativas. En su artículo 7 señala expresamente: “Las meras expectativas no forman derecho”.

En la práctica las normas de la Ley de Efecto Retroactivo (en adelante “LER”) sólo se aplican cuando una ley nueva no consagra disposiciones transitorias que demarquen el dominio de sus normas en relación con las de la ley antigua. Únicamente, en este caso, los jueces están obligados a ceñirse a las pautas de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes.

Es preciso distinguir entre:

a) Normas sobre las leyes relativas al estado civil de las personas.

El estado civil es la calidad o posición social más o menos permanente de un individuo, en orden a sus relaciones de familia, en cuanto le confiere o impone determinados derechos y obligaciones civiles. Hay estado civil de soltero, de casado, de viudo, de padre o de hijo.

La LER dispone que el estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsiste aunque ésta pierda después su fuerza; pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinan a la ley posterior, sea que ésta otorgue nuevos derechos o imponga nuevas obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos.

En cuanto a las expectativas, la nueva ley no está obligada a respetarlas: la posibilidad que tenían las personas para adquirir un estado determinado, puede truncarlas la ley al exigir otras condiciones o requisitos.

b) Leyes sobre la capacidad de las personas naturales.

La **capacidad de goce**, esto es, la aptitud para adquirir derechos y obligaciones, queda sometida a las nuevas leyes.

La **capacidad de ejercicio**, esto es, la aptitud legal de una persona para ejercer por sí sola sus derechos sin el ministerio o autorización de otra; adquirida bajo la vigencia de una ley, no se pierde por efecto de una nueva ley que exija otros requisitos para tener dicha capacidad.

Esta solución está en pugna con la teoría de los derechos adquiridos y de las meras expectativas y, al contrario, se acerca más a la teoría de Roubier.

c) Leyes sobre las personas jurídicas.

La LER señala en su artículo 10: **“La existencia y los derechos de las personas jurídicas deben sujetarse a las mismas reglas que respecto al estado civil de las personas naturales que prescribe el artículo 3 de la presente ley”.**

De acuerdo con la disposición transcrita, tenemos que la personalidad jurídica una vez obtenida subsiste bajo el imperio de una nueva ley, aunque ésta exija requisitos diferentes para constituirla; pero los derechos y obligaciones de las personas jurídicas se subordinarán a la ley posterior, sea que modifique o derogue la antigua.

d) Leyes sobre derechos reales.

El artículo 12 de la LER dispone que todo derecho real adquirido bajo el imperio de una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo la vigencia de otra, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecen las disposiciones de la nueva ley.

e) Leyes sobre posesión.

Las leyes sobre posesión son retroactivas, porque la posesión constituida bajo una ley anterior, no se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios o requisitos señalados por ésta, conforme al artículo 13 de la LER.

f) Leyes relativas a los actos y contratos.

Los contratos se rigen por las leyes vigentes al tiempo de su celebración, las cuales se entienden incorporadas en ellos conforme al artículo 22 de la LER. Por lo tanto, es la antigua ley la que rige tanto los requisitos externos como los requisitos internos de los actos y contratos y, aún más, los efectos de dichos actos en el futuro.

La norma de que se entienden incorporadas a los contratos las leyes vigentes al tiempo de su celebración tiene dos excepciones: primero las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de los contratos, y segundo las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellos, pues tal infracción debe castigarse con arreglo a la ley bajo la cual se haya cometido.

g) Leyes sobre la prueba de actos y contratos.

El artículo 23 de la LER señala: **“Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra por los medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere”.**

h) Leyes relativas a las sucesiones.

En cuanto a la sucesión testada, las solemnidades externas se rigen por la ley coetánea a su otorgamiento. Respecto a las solemnidades internas o de fondo, ellas deben estar conformes con la ley vigente a la época en que muera el testador, que es cuando se produce legalmente la delación de las asignaciones. En consecuencia, las leyes vigentes a la época de la muerte del testador prevalecen sobre las anteriores que reglan la incapacidad o indignidad de los herederos o asignatarios, las legítimas, las mejoras, porción conyugal y desheredaciones, conforme al artículo 18 de la LER. Si el testamento contuviere disposiciones que según la ley bajo la cual se otorgó no deberían llevarse a efecto, lo tendrán sin embargo, siempre que ellas no se hallen en oposición con la ley vigente al tiempo de morir el testador.

En cuanto a la sucesión intestada, respecto a los requisitos de fondo se debe estar a lo señalado respecto a la sucesión testamentaria. De ello se desprende que el sujeto que era incapaz de heredar según la ley antigua, puede recibir la asignación si a la época de la apertura de la sucesión lo considera capaz la ley nueva. Por el contrario, el que era capaz de suceder conforme a la ley antigua no podrá recoger la herencia si en el instante de la delación, que es a la muerte del causante, resulta incapaz con arreglo a la nueva ley.

i) Leyes sobre procedimiento.

El artículo 24 de la LER señala: **“Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.**

j) **Leyes sobre prescripción.**

El conflicto surge cuando una parte de la prescripción ha corrido durante la vigencia de una ley y otra posterior viene a modificar las condiciones necesarias para adquirir un derecho o extinguir una acción por prescripción.

La LER, en su artículo 25, soluciona el conflicto otorgando al prescribiente el derecho de elegir entre la prescripción establecida por la ley antigua y la señalada por la ley nueva: **“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley , y que no se hubiera completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que aquella hubiese empezado a regir”.**

El artículo 26 de la LER asimismo señala: **“Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiere principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción”.**

3.2 Efectos de la Ley en el Espacio.



Conforme a los principios básicos del Derecho Internacional Público todo Estado soberano e independiente ejerce dentro de su territorio, en forma absoluta y exclusiva, la potestad legislativa (facultad de dictarse sus propias leyes) y jurisdiccional (facultad de hacerlas cumplir).

Diversas causas hacen que una situación o relación jurídica pretenda ser regida por dos o más legislaciones: **la nacionalidad de los individuos, el cambio de domicilio, la circunstancia de encontrarse un bien en otro país que en el que reside el dueño, el hecho de celebrarse un contrato en un país para que produzca efectos en otro, etc.**

Todos los conflictos de leyes en el espacio giran en torno a dos principios antitéticos: el territorial y el extraterritorial o personal. Según el principio territorial, las leyes se dictan para el territorio y tienen su límite espacial marcado por las fronteras de cada país. Por el contrario, de acuerdo con el principio extraterritorial o personal las leyes se dictan para las personas, y acompañan a éstas fuera del territorio.

La solución extrema de los dos principios expuestos presentaba dificultades e inconvenientes muy graves. Por eso cuando las relaciones sociales y comerciales entre los países se hicieron más continuas y regulares, se comprendió que la ley no podía ser absolutamente territorial ni absolutamente personal, y que había que buscar fórmulas de armonía y conciliación entre los dos opuestos principios.

Se da por supuesto que algunas leyes son territoriales y otras tienen eficacia extraterritorial, pero lo que se discute es: la preponderancia que ha de tener el principio personal o territorial; la fórmula que ha de determinar qué leyes son territoriales y cuáles personales, y el fundamento o justificación del hecho de la autoridad extraterritorial del derecho interno.

Entre las teorías que han intentado dar solución a estos problemas sobresale por su importancia la teoría de los estatutos, que funda parte importante de nuestra legislación. Esta teoría clasifica las leyes en personales, es decir, relativas a las personas; reales, o sea, relativas a los bienes; y las leyes mixtas, que se refieren al mismo tiempo a los bienes y a las personas y particularmente a la forma de los actos jurídicos. Las leyes personales afectan directa y exclusivamente al estado de la persona, o sea, a la universalidad de su condición, de su capacidad o incapacidad para celebrar o ejecutar los actos de la vida civil y si tienen relación con las cosas es sólo accesoriamente. Son leyes reales las que se refieren directamente a las cosas para determinar su naturaleza y el modo de poseerlas o adquirirlas, transferirlas entre vivos y transmitirlas por causa de muerte, sin que ellas tengan relación con el estado o capacidad general de la persona sino es de un modo incidental y accesorio. Las leyes personales tienen aplicación extraterritorial, pues siguen a la persona a cualquier país que vaya, como la sombra del cuerpo. Las leyes reales sólo se aplican en el territorio en el cual están situados los bienes, es decir, tienen carácter local, territorial. En cuanto a las leyes mixtas o relativas a los actos jurídicos, sus efectos se verán más adelante.

El CC adoptó como principio general el de la territorialidad de la ley, conforme al artículo 14 que dispone: **“La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros”**. Dicho principio de la territorialidad se refuerza aún más con la disposición del artículo 16 que señala: **“Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile”**.

Interpretando en forma amplia el citado artículo 14, ello significa que todas las personas que habitan el territorio nacional, sean chilenas o extranjeras, quedan sometidos a la ley chilena desde el punto de vista de sus personas, bienes y actos. El sometimiento del extranjero que vive en nuestro país la ley chilena tiene la compensación de estar asimilado a los chilenos en cuanto a la adquisición y goce de derechos civiles, conforme al artículo 57 del CC.

Como excepciones al principio de la territorialidad, encontramos los siguientes casos de aplicación de ley extranjera en Chile:

- a) Las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño valen en Chile, conforme al artículo 16 inciso 2 del CC. A través de tales estipulaciones la ley extranjera puede aplicarse en el país porque en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes en el lugar y al tiempo de su celebración. Pero lo anterior tiene como limitación que los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile han de arreglarse a las leyes chilenas, de acuerdo al artículo 16 inciso final del CC.
- b) El artículo 955 inciso 2 del CC preceptúa que la sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abra, salvo las excepciones legales.

Como excepciones al principio de la territorialidad, encontramos los siguientes casos de aplicación de ley chilena en el extranjero:

- a) El artículo 15 número 1 del CC señala: “A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecen sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar actos que hayan de tener efecto en Chile”.
- b) El artículo 15 número 2 del CC dispone: “A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, también permanecen sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.

Para determinar la ley que rige a los actos jurídicos, sean estos unilaterales o bilaterales es preciso previamente hacer una distinción **entre los requisitos externos y los internos**. Son **requisitos internos o de fondo los relativos a la capacidad de los sujetos, al consentimiento de ellos, al objeto y a la causa del acto o contrato**. Son **requisitos externos o de forma los relativos a la manera de hacer constar fehacientemente la existencia del acto**. Hay que remarcar que el asunto cobra importancia cuando los actos se realizan en el extranjero y ellos han de tener efectos en Chile.

La ley chilena acoge la regla universalmente consagrada según la cual la forma de los actos, los requisitos externos, se rigen por la ley del lugar en que se otorgan o celebran, regla que se expresa en el adagio latino *lex locus regit actum*. Por lo tanto, es aceptada como regla general que las solemnidades se rigen por la ley del país en que se celebran los actos jurídicos. Nuestra Corte

Suprema ha declarado que el principio locus regit actum es de carácter general, se refiere a todo acto o contrato y a todo instrumento, sea público o privado.



Sin embargo, en el ordenamiento jurídico chileno el principio locus regit actum no es una regla obligatoria, sino una norma facultativa. Los nacionales pueden en el extranjero sujetarse a las leyes chilenas para realizar actos que hayan de tener efecto en Chile, acudiendo a los funcionarios diplomáticos o consulares que estén autorizados para desempeñar en estos casos las funciones de Ministro de Fe.

Asimismo como excepción al principio se señala el artículo 18 del CC que prescribe que cuando las leyes chilenas exigen instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valen las escrituras privadas cualquiera sea la fuerza de ellas en el país en que hayan sido otorgadas. Sin embargo se rebate que esta disposición no es una excepción al principio del lex locus regit actum porque no se refiere a los instrumentos públicos y a las escrituras privadas como formas o solemnidades de un acto jurídico sino como prueba del mismo.

En cuanto a las leyes que rigen los requisitos de fondo de los actos, entre nosotros se concluye que todos estos requisitos, salva una excepción, se rigen por la ley del lugar en que se otorga en acto o contrato, de acuerdo al artículo 16 inciso 2 del CC que da valor en Chile a las estipulaciones contenidas en los contratos válidamente otorgados en país extraño.

La excepción de la regla que aplica a los requisitos internos la ley del país en el que el acto se otorga se halla establecida en el precepto que somete a la ley patria la capacidad y el estado de los chilenos que ejecutan ciertos actos en el extranjero que han de tener efecto en nuestro país, conforme al artículo 15 número 1 del CC.

Por último, debe señalarse que los contratos válidamente otorgados en país extraño producen efectos en Chile, es decir, los derechos y obligaciones que ellos engendran pueden hacerse valer en nuestro país, pero para cumplirse en él deben arreglarse a la ley chilena conforme al artículo 16 incisos 2 y 3 del CC. Que esos efectos, los derechos y obligaciones que deriven del contrato deban arreglarse a la ley chilena, quiere decir que han de conformarse a ésta.

Tema 4: Otros Asuntos de Interés.

4.1 Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo.

Derecho Objetivo es el conjunto de normas imperativas que, para mantener la convivencia pacífica y ordenada de los hombres en la sociedad, regulan las relaciones de ellos determinadas por esas mismas normas.

Derecho Subjetivo es el señorío o poder de obrar reconocido u otorgado por el derecho objetivo a la voluntad de la persona para la satisfacción de los propios intereses jurídicamente protegidos.

4.2 Ordenamiento Jurídico.

El ordenamiento jurídico es el derecho positivo de una sociedad, mirado como un todo unitario y ordenado porque la multitud de normas jurídicas de Estado o de cualquiera otra sociedad organizada no se encuentran dispersas anárquicamente ni yuxtapuestas, sino que coordinadas y jerarquizadas, formando así un todo unitario ordenado.

El todo unitario de un ordenamiento jurídico agrupa diversos cúmulos de normas referentes a ciertos grandes y determinados géneros de materias: civil, comercial, minero, agrario, laboral, penal, administrativo, procesal, etc.

4.3 Caracteres Particulares de las Normas Jurídicas.

a) Finalidad.	El fin de las normas jurídicas es mantener el orden y la paz social. Este objetivo es el carácter más relevante del Derecho y bastaría para definirlo, pues no hay ningún otro sistema normativo que persiga como propio de su esfera dicha finalidad.
b) Imperatividad.	Las normas jurídicas son imperativas porque expresan una orden, un mandato y no un ruego, un consejo o una sugerencia. Se dirigen a los miembros de la comunidad, que están obligados a acatar el mandato por la conveniencia de hacerlo o por temor a las sanciones que, por lo general, trae la violación o desobediencia de la orden. Hay normas que permiten ellas mismas dejar de lado su mandato, como las normas de orden privado.
c) Heteronomía.	Las normas jurídicas, con relación a los hombres a los cuales se dirigen, son heterónomas porque se siguen o adoptan no por propia voluntad de éstos, como las normas morales o religiosas, sino por imposición de una voluntad ajena exterior, la del creador de la norma.
d) Alteridad o bilateralidad.	La norma jurídica no es una regla de conducta para el individuo aisladamente considerado, no rige el comportamiento de la persona en sí mismo, sino en relación con el de los otros, sus semejantes. No se dan para el hombre en soledad sino para sus relaciones con otros hombres, entre los cuales se establecen

	derechos y deberes, al revés de las normas morales y las de uso social que sólo crean deberes.
e) Abstracción.	No prevén ellas casos concretos sino situaciones tipo, que es la hipótesis abstracta que se aplica cuando se produce un hecho concreto que corresponde al modelo o esquema suyo, desencadenándose entonces los efectos que la norma establece.
f) Generalidad.	Esto quiere decir que se dirigen a todos los coasociados que, durante el tiempo de su vigencia, encajen en las hipótesis por ellas previstas. La generalidad de las normas jurídicas responde al principio de igualdad ante la ley, pues la regla es la misma para todos, sin favorecer o perjudicar determinadamente a nadie.
g) Coercibilidad.	En el sentido que admiten la posibilidad del cumplimiento forzoso cuando es necesario y factible. La coerción de las normas consiste en la amenaza de sanción que acompaña el mandato contenido en ellas en caso de no ser observado u obedecido espontáneamente. Pese a lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico podemos encontrar casos excepcionales de normas desprovistas de sanción, por ejemplo, el artículo 222 del CC que prescribe que los hijos deben respeto y obediencia a sus padres.
h) Carácter Estatal.	Esta expresión tiene dos significados. Uno quiere decir que el Estado crea o reconoce las normas obligatorias generales, esto es, iguales para todos a cuantos afecte, como quiera que aspira mediante tales normas a realizar la justicia. El segundo significado apunta a que es el Estado el que garantiza el respeto y la observancia del ordenamiento jurídico.

4.4 Clasificación de las Normas Jurídicas.

a) Normas de derecho público y normas de derecho privado.

Son normas de derecho público aquellas que regulan la organización y actividad del Estado y demás entes públicos menores, sus relaciones entre sí o con los particulares, actuándole Estado o dichos entes en cuanto sujetos dotados de poder soberano o público. Hay una relación de desigualdad ya que los particulares actúan como subordinados del Estado.

Son normas de derecho privado aquellas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, o la de éstos con el Estado o los demás entes políticos e cuanto los últimos no actúan como poder

político o soberano, sino como si fueran particulares, o, por fin, las relaciones de estos mismo entes políticos entre sí en cuanto obran como si fueran particulares y no como poder político o soberano. Las relaciones se establecen entre sujetos que intervienen en un plano de igualdad.

b) Normas de orden público y normas de orden privado.

Las normas de orden público son aquellas a las cuales, en sus relaciones, los sujetos deben ceñirse ineludiblemente, no pudiendo modificarlas ni sustituirlas por otras de su creación. Envuelven un predominante interés colectivo.

Las normas de orden privado son las que, en sus relaciones, las partes pueden modificar o sustituirlas enteramente por otras elaboradas por ellas mismas. Envuelven un puro interés de los sujetos de la relación y son, pues, supletorias de la voluntad de las partes.

Suele decirse que las normas de orden público son irrenunciables y renunciables las de orden privado. Lo mismo quiere manifestarse cuando se afirma que las normas de orden público son inderogables por las partes y derogables por ellas las normas de orden privado.

c) Normas de derecho común y normas de derecho especial.

Son normas de derecho común las dictadas para la generalidad de las personas, la totalidad de las cosas o la totalidad de las relaciones jurídicas.

Son normas de derecho especial aquellas dictadas para una determinada clase de personas, cosas o relaciones jurídicas, en relación de ofrecer esa determinada clase peculiaridades que exigen apartarla de la disciplina general de las normas comunes.

Importa esta clasificación porque las normas especiales se aplican con preferencia a las comunes, por el principio de la especialidad consagrado en los artículos 4 y 13 del CC.

d) Normas imperativas, prohibitivas y permisivas.

Son normas imperativas aquellas que ordenan o mandan hacer algo, imponen un determinado actuar.

Son normas prohibitivas aquellas que mandan no hacer algo, ordenando una omisión.

Son normas permisivas aquellas que permiten hacer o no hacer algo. La obligatoriedad de estas normas radica en el hecho de que las demás personas deben tolerar la acción u omisión de otra persona, por ejemplo, el artículo 1117 del CC que permite al legatario elegir entre muchas cosas la especie legada.

e) Normas interpretativas y supletorias o integradoras.

Son **normas interpretativas o explicativas las que fijan el sentido**, extensión o contenido de otras normas, o bien sirven de regla para su interpretación o de actos jurídicos.

Las **normas supletivas o integradoras son las que suplen vacíos** o lagunas del contenido de la declaración de los particulares en un acto jurídico.

f) Normas sustantivas o materiales y normas adjetivas o formales.

Las normas sustantivas o materiales son aquellas que tienen una finalidad propia y subsistente por sí, fijando la regla de conducta y las facultades y deberes de cada uno.

Son normas adjetivas o formales aquellas que poseen una existencia dependiente y subordinada pues sólo tienden a facilitar los medios para que se cumpla la regla establecida, garantizando el respeto de las facultades y deberes atribuidos por normas sustantivas.

Tema 5: Fuentes del Derecho.

En general, por fuente del derecho se entiende toda constancia escrita o verbal que permita captar la existencia de normas jurídicas.

Las fuentes del derecho pueden ser **formales o materiales**. **Fuentes formales son los modos o formas concretas en que se manifiestan las normas de un ordenamiento jurídico dado**. **Fuentes materiales son las manifestaciones escritas o verbales que no establecen normas jurídicas sino que aportan elementos para el conocimiento de ellas, su cabal interpretación y aplicación**.

Se consideran fuentes formales del derecho las siguientes:	a) La ley, y b) La costumbre.
Se consideran fuentes materiales del derecho las siguientes:	a) La doctrina, y b) La jurisprudencia.

Tema 6: Código Civil Chileno.

Código es toda ordenación sistemática de normas legales relativas a una determinada rama del derecho o a una parte orgánica de él.

La elaboración del CC comenzó con la llegada a **Chile en 1829 del venezolano Andrés Bello** que participó en toda la gestación de este cuerpo legal. Los diversos proyectos fueron todas obras suyas, con algunas modificaciones introducidas por la Comisión que lo examinaba.

Al principio hubo proyectos que no abarcaban todas las materias propias del CC sino sólo algunas. Se crearon comisiones revisoras que después de alguna labor, se desintegraron y extinguieron. Estos proyectos, con las enmiendas correspondientes sugeridas por aquellas comisiones, fueron publicados en los años 1841 y 1845.

Luego se presentó en proyecto de CC completo de 1853. El gobierno nombró una comisión revisora de dicho proyecto, al mismo tiempo que ordenó que fuera publicado y distribuido para su estudio. La comisión revisora realizó más de trescientas sesiones e introdujo numerosas innovaciones, gran parte de ellas propuestas por el propio Bello. La comisión revisora no dejó actas de sus sesiones, aunque Bello las realizó privadamente.

El proyecto de 1853 pasó por una doble revisión. La forma en que quedó después de la primera, se llama el proyecto inédito, pues no fue publicado hasta 1890, al incorporarse a las obras completas de Bello.

El proyecto de 1853 fue sometido a un segundo estudio y en seguida se presentó por el gobierno a la deliberación del Congreso Nacional en 1855, y toma el nombre de Proyecto Definitivo.

El Congreso Nacional, después de algunas deliberaciones, aprobó el CC en conjunto, no artículo por artículo. La ley aprobatoria fue promulgada el 14 de diciembre de 1855 y se ordenó que el CC empezara a regir el 1 de enero de 1857.

El CC chileno comprende un título preliminar y cuatro libros, seguidos del título final. Cada libro se divide en títulos y muchos de éstos en párrafos. El CC se distribuye de en artículos, desde el 1 al 2524, más el artículo final. En su composición se distingue:

- a) **El título preliminar**, que trata todo lo relativo a la ley, y da la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes.

- b) **El libro I se titula “De las personas”** y trata de las personas naturales en cuanto su nacionalidad y domicilio, del principio y fin de su existencia, del matrimonio, de los derechos y deberes para con los hijos, de las pruebas del estado civil, de la emancipación, de las tutelas y curadurías, de las personas jurídicas, etc.
- c) **El libro II se titula “De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce”** y trata de las variadas clases de bienes, del dominio o propiedad de los diversos modos de adquirir ésta, de la posesión de los bienes, de las limitaciones al dominio, la reivindicación y de las acciones posesorias.
- d) **El libro III se denomina “De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos”** y trata de la sucesión intestada, o sea, señala quienes heredan los bienes del difunto cuando éste no ha hecho testamento, de los testamentos, de las asignaciones testamentarias, de las asignaciones forzosas, de los ejecutores testamentarios, de la partición o reparto de bienes del difunto, del pago de las deudas hereditarias y testamentarias, de las donaciones entre vivos.
- e) **El libro IV titulado “De las obligaciones en general y de los contratos”** habla de las diferentes clases de obligaciones, del efecto de ellas, de los modos de extinguirlas, de su prueba, de las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal, de la separación de bienes y del régimen de participación en los gananciales, de las diversas clases de contratos, de su interpretación, de los cuasicontratos, de los delitos y cuasidelitos civiles, de la fianza, la prenda, la hipoteca, la anticresis, la transacción, de la prelación de créditos y la prescripción.
- f) **El título final consta de un solo artículo que se refiere a la observancia del CC.**

El CC se caracteriza por ser eminentemente práctico, ajeno a la formulación de normas abstractas. Asimismo, destaca en él la claridad de su lenguaje y el no uso de términos técnicos sin antes precisarlos o definirlos.

Los principios que inspiran al CC son los siguientes:

- a) La libre circulación de los bienes.
- b) La defensa de la propiedad individual.
- c) La protección de la buena fe.
- d) El reconocimiento de la autonomía de la voluntad.

- e) La reparación del enriquecimiento sin causa.
- f) El de igualdad de todos los habitantes de nuestro territorio.
- g) La responsabilidad tanto contractual con extracontractual.

Dentro de los mayores meritos del CC se señala el establecimiento **del principio de igualdad entre nacionales y extranjeros respecto de la adquisición y goce de los derechos civiles.** Además fue el primero en legislar de manera completa y precisa sobre las personas jurídicas. En el campo del derecho internacional consagró muchos principios que sólo tiempo después fueron recogidos en su seno por las leyes de otros países. También se destacan los progresos en el campo de la propiedad raíz y en la sucesión por causa de muerte.

Se le critica no haberse ocupado de la propiedad literaria, dejando su regulación para una ley posterior. También se critica haber presumido de derecho la concepción y el empleo del término demencia en vez de enfermedad mental.

Unidad 2: Personas Naturales y Jurídicas

Tema 1: Personas Naturales.

1.1 Sujetos del Derecho.

En general, reciben el nombre de **sujetos de derecho todos los seres que, conforme al ordenamiento legal, están dotados de capacidad jurídica, llamada también capacidad de goce, o sea, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones**. Son de dos clases; primero, personas naturales o físicas; y, segundo, **personas jurídicas o morales**.

1.2 Principio de la existencia de las personas naturales.

Conforme al artículo 55 del CC, **son personas físicas o naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición**.

El CC dispone en el artículo 74 lo siguiente: **“La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”**.

Para que el nacimiento constituya un principio de existencia legal se requieren tres condiciones:

- a) La **separación del niño respecto de su madre**, sea que el desprendimiento del feto del claustro materno se obtenga natural o artificialmente por medios quirúrgicos, pues la ley al respecto no distingue.
- b) La **separación debe ser completa**. Esto significa, en opinión de algunos, que ningún vínculo haya entre la madre y el hijo, ni siquiera el del cordón umbilical. Pero en el sentir de otros, para que haya separación completa, basta que la criatura salga toda del seno materno, sin que importe que el cordón umbilical esté cortado o no.
- c) La **criatura debe sobrevivir a la separación un momento siquiera**. Hay casos dudosos sobre si la criatura vivió o no; para resolverlos se recurre a ciertas pericias médicas que, generalmente, tienden a establecer si la criatura, respiró o no, pues la respiración es un signo vital por excelencia. La circunstancia de que para ser persona basta nacer vivo es lo

que sostiene la doctrina de la vitalidad. En otras legislaciones se exige además la viabilidad, según lo cual no basta el hecho de la vida, sino que es necesario además que la criatura haya nacido viable. Esto implica que la criatura debe venir al mundo con la aptitud para seguir viviendo, lo que supone la madurez suficiente del feto.

La determinación *de si la criatura vivió o no siquiera un instante es de gran importancia, sobre todo en materia de donaciones y herencias*, por ejemplo, la donación que se hace al primer niño que nazca en año nuevo en la ciudad.

No obstante que la existencia legal **sólo comienza con el nacimiento**, existe una realidad, cual es la de la criatura ya concebida, realidad que no ha podido ser ignorada por el derecho, así se distinguen las siguientes consideraciones:

- a) La ley protege la vida del nasciturus, o sea, del que está por nacer, en el primer número del artículo 19 de la Constitución Política de la República y en el artículo 75 del CC. El ordenamiento jurídico prohíbe y sanciona toda maniobra destinada a impedir que nazca la criatura concebida. Ningún aborto, ni siquiera el terapéutico, está permitido, conforme al artículo 119 del Código Sanitario, texto establecido por la Ley No. 18.826, de 15 de septiembre de 1989. El Código Penal fija las penas del delito de aborto en sus artículos 342 a 345.
- b) Se protegen los derechos eventuales del que está por nacer, conforme al artículo 77 del CC. Se habla de derechos eventuales porque están sujetos al evento de que la criatura adquiera existencia legal.

En cuanto a la época de la concepción, el artículo 76 del CC consagra una presunción de derecho, luego no admite prueba en contrario.

1.3 Fin de la existencia de las personas naturales.

1.3.1 Muerte Natural.

Tal como el nacimiento determina el comienzo de la existencia legal de una persona, la muerte implica el fin de la existencia de la misma. La muerte puede ser natural o presunta. El artículo 78 del CC dispone: **“La persona termina en la muerte natural”**.

La muerte es la terminación de las funciones vitales del individuo. Es un concepto claro, aunque hoy día se habla también de muerte clínica, y se entiende por tal un estado en que se conservan

algunas funciones vitales, especialmente vegetativas, que se mantienen, por lo general, en forma artificial, pero, no obstante ellas, el individuo ha perdido toda conciencia o proceso intelectual. El concepto de muerte clínica o cerebral ha sido aceptado por la Ley No. 18.173, de 15 de noviembre de 1982, que autoriza el transplante de órganos de cadáveres con fines terapéuticos. En tal caso, el certificado de defunción se otorgará cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará mediante la certeza diagnóstica de la causa del mal y, a lo menos, dos evidencias electroencefalográficas.

1.3.2 Trascendencia jurídica de la muerte.

El fin de la persona natural, su muerte, produce importantes consecuencias jurídicas: **transmisión de los bienes del fallecido a sus herederos; disolución del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges; extinción de los derechos intransmisibles, como el de pedir alimentos, los derechos de usufructo, uso o habitación; término de ciertos contratos por la muerte de uno de los contratantes, como por ejemplo, sociedad, mandato, comodato; extinción de la oferta de celebrar contrato por la muerte del proponente; término de algunos cargos por la muerte del que los desempeña, como por ejemplo, guardadores, albaceas; extinción de algunas acciones civiles, como la de nulidad de matrimonio, acción de divorcio; etc.**

1.3.3 Comurientes.

El determinar con precisión el momento en que una persona muere, puede tener gran importancia jurídica sobre todo en materia sucesoria. Al respecto nuestro CC, siguiendo la pauta del derecho romano, establece en su artículo 79 lo siguiente: *“Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiese saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todo caso como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras”.*

La presunción de los comurientes es legal y puede, por lo tanto, destruirse probando por cualquiera de los medios que admite la ley, que cierta persona falleció antes o después que la otra u otras.

1.4 Muerte Presunta.

Muerte presunta es la declarada por el juez, en conformidad a las reglas legales, respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Como requisito previo, se debe justificar que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias han transcurrido a lo menos cinco años, conforme al primer número del artículo 81 del CC.

Entre las pruebas destinadas a justificar el desaparecimiento es de rigor la citación del ausente que debe repetirse hasta por tres veces en el periódico oficial, corriendo más de dos meses entre cada dos citaciones de acuerdo al segundo número del artículo 81 del CC.

La declaración puede ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en ella, con tal que haya transcurrido tres meses al menos desde la última citación, conforme al tercer número del artículo 81 del CC.

Para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores debe ser oído el defensor de ausentes. A petición de éste o de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, puede exigir el juez además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan según lo dispuesto en el cuarto número del artículo 81 del CC.

La sentencia debe publicarse en el Diario Oficial de conformidad con el quinto número del artículo 81 del CC.

1.4.1 Día presuntivo de muerte del desaparecido.

Con respecto a cuál será el día presuntivo de la muerte, como de este día pueden depender los derechos de diversas personas, la ley, para evitar arbitrariedades, ha señalado uno determinado; ordena que se ha de fijar como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias, conforme al sexto número del artículo 81 del CC. Las excepciones a dicha regla general son las siguientes:

- i. Cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro semejante el juez fijará como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro o, no siendo enteramente determinado ese día, un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso conforme al séptimo número del artículo 81 del CC.

- ii. El mismo criterio se aplica en los casos de pérdida de una nave o aeronave, conforme al octavo número del artículo 81 del CC.
- iii. Cuando el desaparecimiento ha coincidido con un sismo, catástrofe o fenómeno natural será la fecha de tal evento la que el juez fijará como día presuntivo de la muerte, conforme al noveno número del artículo 81 del CC.

En la muerte presunta se distinguen en general tres períodos: primero, el de mera ausencia; segundo, el de posesión provisoria de los bienes del desaparecido; y, tercero, el de posesión definitiva de dichos bienes. El período de posesión provisoria no está siempre presente.

1.4.2 Período de mera ausencia.

Comienza desde que han dejado de tenerse noticias del ausente. Es un estado de hecho en el cual el objetivo fundamental es proteger los derechos del ausente, para lo cual se tiende a la administración de sus bienes. Si el ausente ha dejado apoderados o representantes con poder suficiente o tiene un representante legal, ellos administran los bienes y no se adoptará medida especial alguna conforme al artículo 83 del CC. Si no existen tales apoderados o representantes procede nombrar un curador de los bienes del ausente en conformidad a los artículos 473 y siguientes del CC.

El período de mera ausencia dura normalmente cinco años, pero:

- i. Durará un año si la desaparición se produjo en un sismo o catástrofe, conforme al noveno número del artículo 81 del CC.
- ii. Durará seis meses si provino de la pérdida de una nave o aeronave, conforme al octavo número del artículo 81 del CC.

1.4.3 Período de posesión provisoria.

Transcurridos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, el juez dicta una resolución concediendo la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, conforme a la segunda parte del sexto número del artículo 81 del CC.

El período de la posesión provisoria de los bienes del desaparecido no existirá en los dos casos de excepción señalados; cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sucedió otro peligro semejante conforme al séptimo número del artículo 81 del CC, o bien, si cumplidos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, se pruebe que han transcurrido setenta desde el

nacimiento del desaparecido, conforme a la primera parte del artículo 82 del CC. En estas situaciones se concede de inmediato la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.

En el período de posesión provisoria la ley considera el interés de las personas a quienes se habrían transmitido los bienes del desaparecido si éste hubiese muerto realmente, y entrega a los herederos presuntivos del desaparecido la posesión provisoria de los bienes, conforme al primer inciso del artículo 84 del CC.

Los **efectos del decreto de posesión provisoria** son los siguientes:

- i. En virtud del decreto de posesión provisoria queda disuelta la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales, según cual hubiere habido con el desaparecido.
- ii. Debe procederse a la apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno y debe darse la posesión provisoria a los herederos presuntivos conforme a los artículos 84 y 85 del CC. Se entiende por herederos presuntivos del desaparecido los testamentarios o legítimos que lo eran a la fecha de la muerte presunta. El patrimonio en que se presume que suceden, comprende los bienes, derechos y acciones del desaparecido, cuáles eran a la fecha de la muerte presunta.
- iii. Cada uno de los poseedores provisorios debe prestar caución de conservación y restitución, y hace suyos los respectivos frutos e intereses, conforme al artículo 89 del CC. Los herederos presuntivos administran y usufructúan los bienes del desaparecido, y deben ante todo formar un inventario solemne de los bienes, o revisar y rectificar con la misma solemnidad el inventario que exista conforme al artículo 86 del CC.
- iv. Los herederos presuntivos, poseedores provisorios, representan a la sucesión en las acciones y defensas contra terceros, conforme al artículo 87 del CC.
- v. Pueden los poseedores provisorios vender desde luego una parte de los muebles o todos ellos, si el juez lo cree conveniente, oído el defensor de ausentes, conforme al artículo 88 del CC. En cuanto a los bienes raíces del desaparecido, no pueden enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o utilidad evidente, declarada por el juez con conocimiento de causa y con audiencia del defensor de ausentes. La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido debe hacerse en pública subasta.

La **posesión provisoria puede terminar por las siguientes razones**:

- i. Con el decreto de posesión definitiva.
- ii. Con la reaparición del ausente.
- iii. Cuando llega a saberse con certeza la fecha verdadera de la muerte del desaparecido.

Obvio es que en estos dos últimos casos no sólo termina el período de posesión provisoria, sino todo el proceso de la muerte presunta.

1.4.4 Período de posesión definitiva.

El período de posesión definitiva se inicia con el decreto del juez que concede esta posesión de los bienes del desaparecido. Por regla general, el juez concede esta posesión transcurridos que sean diez años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez años, la edad del desaparecido si viviese, conforme a la segunda parte del artículo 82 del CC.

Los **efectos del decreto de posesión definitiva son los siguientes:**

- i. Si no ha precedido posesión provisoria, por el decreto de posesión definitiva se abre la sucesión del desaparecido según las reglas generales, conforme al inciso final del artículo 90 del CC.
- ii. Se cancelan las cauciones y cesan las restricciones que antes tenían, que les impedía vender o gravar los bienes, conforme a los incisos primero y segundo del artículo 90 del CC.
- iii. Decretada la posesión definitiva, todos los que tienen derechos subordinados a la muerte del desaparecido, pueden hacerlos valer como en el caso de verdadera muerte, conforme al artículo 91 del CC. Así, el legatario puede reclamar la cosa legada; el fideicomisario, la cosa de la cual el desaparecido era propietario fiduciario; el nudo propietario, la cosa de que era usufructuario el desaparecido, etc.
- iv. Se hace la partición de los bienes en conformidad a las reglas generales que rigen esta materia.

Finalmente, es efecto del decreto de posesión definitiva la disolución del matrimonio del desaparecido (ver LMC).

La ley autoriza para pedir la rescisión del decreto de posesión definitiva en los siguientes tres casos:

- i. Si se tuvieren noticias exactas de la existencia del desaparecido.
- ii. Si se tuvieren noticias exactas de la muerte real del mismo.
- iii. Si el presunto muerto reapareciere.

El decreto de posesión definitiva puede rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere, o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento, o de su cónyuge por matrimonio contraído en la misma época, conforme al artículo 93 del CC.

Las reglas que deben seguirse en la rescisión del decreto de posesión definitiva están contenidas en el artículo 94 del CC y son las siguientes:

- i. El desaparecido puede solicitar la rescisión en cualquier tiempo que se presente, o que haga constar su existencia. Al respecto, ninguna clase de prescripción corre contra el desaparecido.
- ii. Las demás personas no pueden pedir la rescisión sino dentro de los respectivos plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera muerte. Las demás personas a que alude esta regla son los legitimarios y el cónyuge. En contra de ellas corre la prescripción según las normas generales.
- iii. El beneficio de la rescisión aprovechará solamente a las personas que por sentencia judicial lo obtengan.
- iv. En virtud del beneficio de la rescisión los bienes se recobrarán en el estado en que se hallen, respecto de los herederos presuntivos, subsistiendo las enajenaciones, las hipotecas y demás derechos reales constituidos legalmente en ellos, respecto de los terceros.
- v. Para toda restitución los demandados se consideran poseedores de buena fe, y por ende, de acuerdo con las normas generales dadas en los preceptos que tratan de la reivindicación, tienen derecho al abono de las mejoras necesarias y útiles que hubieren efectuado en los bienes poseídos. La presunción de buena fe admite la prueba contraria.
- vi. El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe, lo que se considera una notable excepción al artículo 1459 del CC.

1.4.5 Inscripciones en el Registro Civil y en el Conservador de Bienes Raíces relacionadas con la muerte presunta.

Las sentencias ejecutoriadas que declaran la muerte presunta deben inscribirse en el libro de defunciones del Registro Civil, en la comuna correspondiente al tribunal que hizo la declaración conforme al quinto número del artículo 5 de la Ley No. 4.808. Si la sentencia no se inscribe, no puede hacerse valer en juicio, conforme al artículo 8 de la misma ley.

El decreto que confiere la posesión definitiva de los bienes del desaparecido debe inscribirse en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, conforme al cuarto número del artículo 52 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. La inscripción se hace en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la comuna del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, o sea, la comuna en que se decretó la muerte presunta. Si el decreto no se inscribe, es inoponible frente a terceros.

1.5 Elementos Esenciales de la Personalidad.

La teoría clásica llama atributos de la personalidad a ciertos elementos necesariamente vinculados a toda persona e indispensables para el desenvolvimiento de ella como sujeto de derechos. Los atributos de la personalidad son calidades que corresponden a todo ser humano sólo en virtud de ser tal.

Dichos atributos son propios tanto de las personas naturales como de las morales o jurídicas, con ciertas salvedades. Son los siguientes:

- Capacidad de goce.
- Nacionalidad.
- Nombre.
- Estado civil, del cual carecen las personas jurídicas.
- Domicilio.
- Patrimonio.
- Derechos de la personalidad.

1.6 Capacidad.

Se distinguen en nuestro ordenamiento jurídico dos tipos de capacidad: una que consiste en la aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones, denominada comúnmente **capacidad de goce**, y otra, que consiste en la aptitud de las personas humanas para obrar por sí mismas en la vida civil, denominada **capacidad de obrar o simplemente de ejercicio**.

La **capacidad de goce** es consustancial al concepto de persona, toda vez que lo que constituye en esencia la personalidad es la posibilidad jurídica de adquirir derechos y obligaciones. De modo que es inconcebible que pueda existir una persona que carezca de esta capacidad o que teniéndola carezca de personalidad. En realidad, uno y otro concepto se identifican. No hay, entonces, incapacidades de goce absolutas. Sólo existen en nuestro derecho incapacidades para adquirir un derecho en particular, fundadas en principios de orden público o en consideraciones de índole moral. Asimismo, y por aplicación de estos mismos principios, no todas las personas tienen el mismo grado de aptitud para adquirir derechos y obligaciones, aunque se debe reconocer que en la gran mayoría de los casos existe una verdadera igualdad en relación a su capacidad de goce.

La **capacidad de goce consiste**, en esencia, en poder adquirir derechos y contraer obligaciones, en poder usar y gozar de los derechos adquiridos y, finalmente, en poder disponer de los mismos. Los derechos se usan y gozan ejerciendo su titular, por sí mismo o por quien haya designado, las facultades o potestades a que el derecho autoriza, sea que consistan en hechos o actos jurídicos, sea que se trate de la realización de hechos sin relevancia jurídica. Este ejercicio, que se realiza sin el ministerio o autorización de otros, es lo que denominamos capacidad de obrar.

Como se podrá comprender, **el ejercicio no es una cosa diferente al goce**. Muy por el contrario, es parte del goce, pues se goza a menudo mediante el ejercicio. De manera que lo que llamamos capacidad de obrar es, en el fondo, una parte de la capacidad de goce o jurídica; es aquella parte que consiste en determinar por sí mismo, sin el ministerio o autorización de otro, de qué manera se usará, gozará y dispondrá de los derechos. En otras palabras, la capacidad de goce es el género y la de ejercicio la especie. Quien no tiene capacidad de goce no puede tener nada, no es sujeto de derecho. Quien no tiene capacidad de ejercicio, tiene limitada su capacidad de goce en lo relativo al ejercicio de sus derechos. Finalmente, es menester hacer presente que la capacidad jurídica no es, ella misma, un derecho subjetivo, es más bien el antecedente lógico a los derechos subjetivos, con el contenido más diverso. Es una cualidad jurídica.

1.6.1 Capacidad de ejercicio.

La **capacidad de ejercicio, denominada también capacidad de obrar o de hecho, es la aptitud de las personas humanas para obrar por sí mismos en la vida civil**. El requisito que supone o más bien constituye la capacidad de obrar es la existencia real y concreta de una voluntad capaz de discernir con responsabilidad y con la debida independencia o libertad cuales son los actos jurídicos patrimoniales o extrapatrimoniales que desea realizar.

El principio general establecido en el artículo 1446 del CC es que todas las personas humanas son capaces, salvo aquellas que la ley ha declarado expresamente incapaces. Y el precepto legal precedentemente expuesto significa, también, que cada incapaz, de derecho o de hecho, lo es únicamente en la medida establecida por la ley, y es por esta circunstancia que la incapacidad no puede extenderse por analogía a otros supuestos no previstos en la norma.

El artículo 1447 del CC establece quienes son los incapaces de obrar, al disponer: *“Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos, los disipadores que se hallen bajo*

interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respetos, determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”.

Los dementes y los impúberes son incapaces porque carecen absolutamente de voluntad; los sordomudos que no pueden darse a entender claramente porque su voluntad no puede ser conocida; los menores adultos porque aún teniendo voluntad no se encuentra todavía completamente formada; los disipadores interdictos porque han demostrado una falta total de prudencia en la administración de sus negocios.

El último inciso del artículo 1447 del CC establece que además de las incapacidades mencionadas, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Estas incapacidades especiales o particulares de que habla la ley se encuentran establecidas para proteger a los incapaces o en consideración a la moral, al orden público y a las buenas costumbres. Se discute si ellas serían incapacidades de ejercicio o de goce, y se estima que son de goce y no de ejercicio por cuanto constituyen prohibiciones que impiden la adquisición de ciertos derechos, lo anterior, en la medida que la ley prohíba absolutamente la celebración del respectivo acto o contrato. Desde luego cabe advertir que aquellas prohibiciones que pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no establecen incapacidades de goce, ni tampoco incapacidades de obrar, sino que sólo instituyen determinados requisitos que deben ser cumplidos bajo pena de nulidad.

1.6.2 Efectos de los actos de los incapaces.

El absolutamente incapaz sólo puede actuar en la vida jurídica representado por la persona que tiene su representación legal. Son representantes legales, por ejemplo, el padre o madre bajo cuya potestad vive el incapaz, el tutor o curador del pupilo, etc. Los actos que ejecute un absolutamente incapaz por sí mismo serían, en estricto rigor, inexistentes, pues se supone que el incapaz absoluto carece de voluntad o que no puede expresarla. Sin embargo, nuestra legislación civil sanciona expresamente los actos de los absolutamente incapaces que actúan por sí mismos con la nulidad absoluta, en el segundo inciso del artículo 1682 del CC, lo que significa que el acto nace a la vida del derecho, pero con un vicio que hace posible su declaración de nulidad. Cabe tener presente, finalmente, que conforme al segundo inciso del artículo 1447 del CC los actos de los absolutamente incapaces no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución.

Los relativamente incapaces pueden actuar válidamente en la vida jurídica representados o autorizados por su representante legal. De este modo, el

contrato en que es parte un incapaz relativo puede haber sido celebrado directamente por el representante legal, a nombre del incapaz, o directamente por el incapaz relativo, autorizado por su representante legal. Por excepción la ley permite que los incapaces relativos ejecuten ciertos actos sin necesidad de representación o de autorización, como por ejemplo, en actos personalísimos como el reconocimiento de un hijo. Asimismo, el menor adulto es capaz y goza de autonomía en la administración y gestión de su peculio profesional (246 del CC). Debe, eso sí, recabar autorización judicial para enajenar o gravar los inmuebles. Los actos que ejecuten los relativamente incapaces sin la autorización o representación del representante legal se sancionan con nulidad relativa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 1682 del CC. Sin embargo, y en atención a que la ley considera que los incapaces relativos tienen suficiente juicio y discernimiento, las obligaciones contraídas por éstos tienen la calidad de naturales y pueden ser caucionadas por terceros, conforme a los artículos 1470 y 1472 del CC.

Las convenciones entre particulares que tengan por objeto limitar o extender más allá de los términos de la ley la capacidad de goce o de ejercicio de un individuo son nulas, por cuanto importarán siempre la renuncia a derechos consagrados por normas de orden público que interesan a la sociedad en general, y no sólo al renunciante. Constituye una excepción a los principios señalados el pacto de separación total de bienes celebrado por los cónyuges, pues importa hacer a la mujer plenamente capaz.

1.6.3 La Demencia.

Nuestro CC no define la demencia, pero con esta expresión **se refiere a la situación en que se encuentra una persona que por alteración de sus facultades mentales, carece de la aptitud necesaria para dirigir su persona o para administrar sus bienes**. Sin embargo, la falta de aptitud del demente para administrar competentemente lo suyo debe provenir de una enfermedad mental susceptible de producir tal efecto, y no por actos del individuo, como en la ebriedad.

Todo demente es, sin duda, enfermo mental. Pero no todo enfermo mental es considerado demente por nuestro ordenamiento jurídico, pues para ello es necesario, además, que la enfermedad afecte de tal manera al individuo que le impida dirigir su persona y administrar competentemente sus negocios. De esta manera, la decisión para considerar demente a una persona deberá ser precedida de una investigación científica y práctica que tendrá siempre por objeto determinar las siguientes circunstancias: primero, que la persona adolece de una enfermedad mental; y, segundo, que esa enfermedad mental produce en el individuo una ineptitud para administrar competentemente lo suyo. Determinar si la enfermedad mental impide la competente administración de los bienes propios es, en definitiva, determinar la gravedad de la enfermedad para los fines del derecho privado, y como tal, no constituye sino más bien un problema netamente jurídico de competencia exclusiva del juez.

El artículo 465 del CC establece en forma clara que para ser privado de la administración de sus bienes el adulto debe hallarse en un estado habitual de demencia. Se plantea, entonces, la necesidad de dilucidar si el carácter habitual o permanente de la enfermedad mental es un requisito jurídico indispensable para producir una incapacidad de ejercicio por causa de demencia, situación de gran importancia práctica. Pensamos que tanto los dementes habituales como los no habituales son incapaces absolutos, los primeros siempre y los segundos sólo mientras dura su corto estado de enajenación, tomando en consideración que el artículo 1447 del CC sólo se limita a señalar que son incapaces los dementes, sin agregar ningún otro requisito o condición, de modo que no procede que el intérprete le agregue a la disposición un requisito evidentemente no consentido por el legislador. De esta manera, debemos concluir que la permanencia más o menos prolongada de la enfermedad mental no es un requisito de la incapacidad de ejercicio; sólo lo es para declarar interdicta por tal motivo a una persona.

1.6.4 La interdicción del demente.

El artículo 456 del CC dispone: “El adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos”. **Los requisitos para que una persona pierda el derecho a administrar sus bienes por causa de demencia son los siguientes:**

- i. En primer lugar, debe tratarse de una persona adulta, esto es, mayor de doce años en el caso de las mujeres y mayor de catorce años en el caso de los hombres. Los impúberes son absolutamente incapaces sean o no dementes por lo que no procede privarlos de una administración que jamás han tenido.
- ii. En segundo lugar, debe tratarse, obviamente, de un enfermo mental que se encuentra impedido de administrar competentemente lo suyo y de dirigir su persona.
- iii. Finalmente, la enfermedad mental debe ser habitual.

En conclusión, la habitualidad no es un requisito de la demencia y por consiguientes de la incapacidad. Es, sin embargo, un elemento necesario y un requisito perentorio para privar a una persona de la administración de sus bienes.

1.6.5 Concepto de habitualidad.

Como se ha señalado anteriormente, el concepto de demencia en sentido jurídico no es sinónimo de enfermedad mental, desde el momento que aquél exige como requisito, además, que la enfermedad mental impida administrar competentemente los bienes. Como primera advertencia es menester señalar que lo que debe ser habitual para declarar en interdicción a un demente no sólo es la enfermedad mental que padece, sino también y muy especialmente, el efecto que ella produce, en el sentido de impedir la competente administración de los bienes del demente. **En**

consecuencia, el concepto de habitualidad excluye o no es comprensivo de dos situaciones bien precisas: los periódicos ataques de demencia y el estado pasajero de demencia. Pero debe dejarse establecido que para que la demencia sea habitual no necesita ser continua, por el artículo 456 del CC declara que la interdicción procede aunque tenga intervalos lúcidos. Tampoco se requiere que sea absoluta; sólo requiere que impida la competente administración de los bienes propios.

1.6.6 El juicio de interdicción.

La interdicción es el estado de una persona que ha sido declarada por sentencia judicial incapaz de los actos de la vida civil, privándola de la administración de sus bienes. La interdicción por demencia es una materia contenciosa y la demanda respectiva debe tramitarse conforme a las reglas del juicio ordinario. No puede iniciarse ni seguirse por un procedimiento de oficio. La demanda de interdicción debe notificarse al supuesto demente y si la demencia de éste es manifiesta corresponderá acreditar la circunstancia en el proceso para designar al demandado un curador especial ad litem al que deberá notificársele la referida demanda, conforme al artículo 494 del CC.

El juicio debe iniciarse a solicitud de parte legítima, nunca de oficio, ante el juez de primera instancia del domicilio del presunto demente, y, si hay varios competentes, la demanda debe ser presentada a la Corte de Apelaciones para la designación del juzgado. Conforme al artículo 459 del CC, pueden provocar la interdicción del demente las siguientes personas:

- i. El cónyuge no separado judicialmente del supuesto demente.
- ii. Por cualquiera de los consanguíneos legítimos hasta el cuarto grado del supuesto demente.
- iii. Por los padres, hijos y hermanos del supuesto demente.
- iv. Por el defensor público.
- v. Por el curador del menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría.
- vi. Si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable incomodidad a los habitantes, podrá también hacerlo el procurador de la ciudad, o cualquiera persona del pueblo.

Se ha fallado que las personas mencionadas no tienen el derecho ni la obligación de provocar el juicio de interdicción del pariente que se encuentra en estado de demencia; ello constituye una simple facultad, o sea, la potencia o la virtud para proceder así, facultad que, sin embargo, es una obligación para los ascendientes o descendientes, o para los llamados en segundo grado a la sucesión intestada del demente, bajo pena de ser declarados indignos de suceder al difunto, conforme al artículo 970 del CC.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 461 en relación con el artículo 446 del CC, mientras se decide la causa podrá el juez, en virtud de informes verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las explicaciones del supuesto demente, decretar la interdicción provisoria. Pero cabe advertir que si la demanda no ha sido al supuesto demente, no ha llegado a formalizarse la causa, y sin ella no puede decretarse la interdicción provisoria, desde que ésta sólo procede, como se ha visto, mientras se decida la causa.

1.6.7 Prueba de la demencia.

La prueba de la demencia puede producirse, tanto en el juicio de interdicción como en el pleito en que se demande la nulidad de un acto o contrato por causa de incapacidad absoluta. La demencia es, como se ha señalado, un concepto jurídico que requiere la concurrencia de dos elementos copulativos, a saber, una enfermedad legal que, además, produzca la ineptitud legal para la administración de los bienes. **La prueba debe tener por objeto comprobar la existencia de estos dos requisitos o elementos.**

El artículo 460 del CC dispone: “El juez se informará de la vida anterior y conducta habitual del supuesto demente, y oirá el dictamen de facultativos de su confianza sobre la existencia y naturaleza de la demencia”. Para determinar cuáles son los medios de prueba aptos para comprobar la existencia de la demencia creemos que es menester efectuar las siguientes distinciones:

- i. Se debe distinguir entre la prueba que requiere la demencia actual para los fines de la interdicción, y aquella que requiere la demencia invocada con el objeto de obtener la anulación de un acto o contrato.
- ii. Se debe distinguir, también, y en todo caso, entre la prueba de la enfermedad mental y la prueba de la ineptitud que ella produce para administrar los bienes propios.

La prueba de la existencia de una enfermedad mental para los fines de una interdicción se demuestra por el dictamen de los médicos, esto porque ni los documentos, ni los testigos, ni las presunciones, ni la inspección personal del tribunal son medios de prueba que pueden tener autoridad para dictaminar un tema que es eminentemente técnico. La prueba de la ineptitud para administrar los bienes que es enfermedad mental produce puede demostrarse por todos los medios de prueba que establece la ley, incluso las presunciones. Ello porque el problema en cuestión sólo puede ser apreciado mediante las manifestaciones concretas de la personalidad del supuesto demente y del análisis cierto que una persona con sentido común puede y debe realizar. La prueba de una enfermedad mental y de la ineptitud para administrar los bienes, destinada a comprobar la existencia de demencia para obtener la anulación de un acto jurídico celebrado con anterioridad, puede demostrarse por todos los medios de prueba que establece la ley, incluso las presunciones. Lo anterior porque el caso en comentario no plantea ni con mucho un problema

psiquiátrico, sino sólo una situación en que resulta esencial un juicio sobre la voluntariedad del acto, problema que habrá de resolver el juez con el criterio de la ley. Creemos, finalmente, que en el juicio de interdicción no se puede plantear la duda sobre a cual de las partes le corresponde el peso de la prueba, pues los claros términos del artículo 460 del CC sólo dan lugar para concluir que es el juez quien tiene el deber y la obligación de indagar e investigar lo que sea necesario para la debida resolución del asunto. Distinto es el caso de un juicio de nulidad de un acto o contrato por causa de demencia, pues en tal caso rigen las reglas generales sobre la carga de la prueba, como expresamente lo dispone el artículo 465 del CC.

En lo que respecta a la designación de los médicos, cabe señalar que el CC no establece el número de médicos que deben realizar el examen del supuesto demente, pero como el artículo 460 del CC exige el examen de facultativos, se debe llegar a la conclusión que debe ser más de uno. Los médicos deben ser de confianza del juez, pero nada obsta a que éste deposite su confianza en los médicos propuestos por las partes.

1.6.8 Efectos de la interdicción.

La sentencia que declara la interdicción de una persona por causa de demencia produce dos efectos fundamentales:

- i. Priva al demente de la administración de sus bienes y le nombra un curador general que vele por sus intereses.
- ii. Trae como consecuencia que todos los actos del demente posteriores al decreto de interdicción, son nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido, conforme al primer inciso del artículo 465 del CC.

En lo que respecta al segundo efecto, la ley ha establecido una especie de presunción de derecho en el sentido de que la persona demente o ejecutó el contrato en ese estado, y por consiguiente, no se admitirá prueba destinada a demostrar que obró en un intervalo lúcido y, por ende, en estado de cordura.

La nulidad de los actos del demente posteriores al decreto de interdicción es absoluta, conforme lo dispuesto en el artículo 1682 del CC.

Se señala que al referirse a los actos o contratos del demente, la ley ha entendido indicar todos aquellos que miran a la administración y disposición de los bienes, a todos los actos pecuniarios o patrimoniales. La sentencia del juicio de interdicción no produce efecto retroactivo ni puede producirlo, aún con declaración expresa del juez.

1.6.9 Actos anteriores a la interdicción.

El segundo inciso del artículo 465 del CC expresa que los actos o contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente. Se estima que el legislador pretendió señalar que, para invalidar un acto o contrato celebrado sin previa interdicción, basta con probar que la persona se encontraba demente en la época en que los actos o contratos fueron hechos y no en el preciso momento de su ejecución o celebración. Al juez le bastará con comprobar que el acto celebrado por el supuesto demente es absolutamente irracional, desproporcionado a su objeto, contrario a sus intereses, etc., para darse cuenta que la persona no estaba en su sano juicio, esto es, demente.

1.6.10 Rehabilitación del demente.

La rehabilitación del demente procede si apareciera que ha recobrado permanentemente la razón, conforme al artículo 468 del CC, esto es, cuando el demente cura. Pero formalmente se requiere, además, una declaración judicial que así lo disponga, dictada en un juicio distinto, conforme al segundo inciso del artículo 468 en relación con el artículo 455 del CC. Las personas que pueden pedir el levantamiento de la interdicción y la rehabilitación del demente son las mismas personas que pueden provocar su interdicción.

1.6.11 La Impubertad.

Conforme al artículo 26 del CC **se llama impúber al varón que no ha cumplido catorce años y a la mujer que no ha cumplido doce años.** Pero dentro de los impúberes mismo se distingue entre aquellos que no han cumplido siete años, llamados infantes o niños, y aquellos que sí lo han hecho, reconociendo el artículo 723 del CC a los segundos cierta capacidad en materia posesoria, al disponer que sólo los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad de posesión. Por otra parte, en materia de responsabilidad extracontractual civil, el artículo 2319 del CC establece que no son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años.

Los actos de los impúberes son absolutamente nulos, conforme al segundo inciso del artículo 1682 del CC, y no producen ni siquiera obligaciones naturales y no admiten caución, conforme al segundo inciso del artículo 1447 del CC.

Carecen, por otra parte, de peculio profesional o industrial, pues jamás podrán administrar los bienes que adquieran con el producto de su trabajo, el cual es un requisito esencial del tal peculio.

En relación con la prueba de la impubertad, cabe tener presente que la edad de una persona se prueba con las respectiva partida de nacimiento. En ausencia de dicha prueba se recurrirá a otros documentos o declaraciones de testigos que fijen la época de su nacimiento. Finalmente, en

ausencia de todo lo anterior, se atribuirá al menor una edad media entre la mayor y la menor que aparecieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo, oyéndose el informe de facultativos o de otras personas idóneas, conforme al artículo 314 del CC.

1.6.12 Sordomudos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1447 del CC, es incapaz el sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente, pues el sordomudo que puede hacerlo no está privado de la administración de sus bienes y es plenamente capaz. **Se fundamenta esta incapacidad en que el sordo o el sordomudo está impedido de expresar su voluntad de modo que es imposible conocerla.**

De acuerdo al artículo 470 en relación con el artículo 458 del CC el sordomudo que no puede darse a entender claramente debe ser puesto en interdicción cuando ha llegado a la pubertad. De lo anterior se concluye que resulta necesario obtener una sentencia judicial que declare en interdicción.

Pueden provocar la interdicción del sordomudo las mismas personas a quienes la ley faculta para provocar la interdicción del demente. Los actos del sordomudo posteriores al decreto de interdicción son nulos de nulidad absoluta, pero como el CC nada dice se entiende que podría ser admitida prueba que pretenda demostrar que, al momento del acto, el sordomudo o se había rehabilitado o había aprendido a darse a entender claramente. Por su parte, los actos del sordomudo anteriores al decreto de interdicción son válidos, a menos de probarse que éste adolecía del defecto y no podía darse a entender claramente al tiempo de celebrar el acto o contrato de que se trate.

Conforme al artículo 472 del CC, cesará la curaduría, y por lo tanto, recuperará u obtendrá la administración de sus bienes, el sordomudo que se haya hecho capaz de entender y de ser entendido (por cualquier medio), siempre que concurran las siguientes condiciones:

- i. Que el mismo sordomudo lo solicite.
- ii. Que el juez estime que tiene suficiente inteligencia para la administración de sus bienes.

En consecuencia, nadie sino el sordomudo puede pedir la rehabilitación o, lo que es igual, la cesación de la curaduría. De la misma manera, el juez debe comprobar que el sordomudo que se ha hecho capaz de entender y capaz de ser entendido tenga la suficiente inteligencia para administrar sus bienes.

1.6.13 Disipadores o Pródigos.

Disipador o pródigo es aquel que ha demostrado una falta total de prudencia en la administración de sus bienes, desperdiciando y consumiendo su hacienda o caudal en gastos inútiles y vanas profusiones. La prodigalidad es, por consiguiente, un concepto relativo que requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos:

- i. Los gastos en que ha incurrido el supuesto disipador deben ser considerados excesivos atendido las particularidades de su patrimonio.
- ii. Debe tratarse de gastos que sólo tengan por causa el apego a una vida desordenada, irracional y caprichosa.

Para que proceda la interdicción por causa de disipación debe tratarse de actos y hechos repetidos y habituales, conforme a lo dispuesto en el artículo 445 del CC que señala que la disipación deberá probarse por hecho repetidos que manifiesten una falta total de prudencia. Ahora bien, para que el disipador o pródigo pueda ser considerado incapaz, es condición esencial que se haya dictado el decreto de interdicción por tal motivo. De lo contrario el disipador es plenamente capaz y los actos o contratos que ejecute o celebre serán plenamente válidos. El juicio de interdicción por disipación se rige por similares normas que el de interdicción por demencia, y nos remitimos a lo dicha en esa ocasión.

1.6.14 Efectos de la interdicción.

La sentencia que declara la interdicción de una persona por causa de prodigalidad produce los siguientes efectos:

- i. Provoca la incapacidad relativa del disipador.
- ii. Priva al pródigo de la administración de sus bienes y le nombra un curador.
- iii. Trae como consecuencia que todos los actos o contratos del disipador posteriores al decreto de interdicción adolezcan de nulidad relativa, conforme al segundo inciso del artículo 1682 del CC.

Teóricamente la sentencia debiera producir sus efectos desde el momento en que queda ejecutoriada, pero como el artículo 447 del CC ordena que los decretos de interdicción deben inscribirse y publicarse, se estima que ella empieza a **producir sus efectos desde el momento que se cumplan estas formalidades de publicidad.** La incapacidad del pródigo interdicto sólo se refiere a los actos patrimoniales, de modo que no alcanza a los actos de familia, salvo aquellos que tengan un contenido patrimonial. Así, el pródigo interdicto es plenamente capaz para contraer

matrimonio, para otorgar testamento, etc. No puede, sin embargo, celebrar capitulaciones matrimoniales sin autorización e su curador, conforme al segundo inciso del artículo 1721 del CC.

1.6.15 Rehabilitación del pródigo.

La rehabilitación del pródigo procede cuando se comprobare que puede ejercer la administración de lo suyo sin inconvenientes, conforme al primer inciso de artículo 454 del CC. Formalmente se requiere una declaración judicial que así lo disponga, dictada en juicio distinto, ceñido a las reglas prescritas para el procedimiento ordinario, conforme al artículo 455 del CC. Las personas que pueden pedir el levantamiento y rehabilitación al disipador son los mismos que pueden pedir su interdicción.

1.6.16 Menores Adultos.

Los menores adultos son aquellos que han dejado de ser impúberes y que no han cumplido todavía dieciocho años de edad. En otras palabras, son menores adultos las mujeres mayores de doce y los hombres mayores de catorce que no han cumplido dieciocho años de edad.

Los menores adultos son incapaces relativos porque sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos. La incapacidad relativa del menor se extiende a actos judiciales y extrajudiciales. En efecto, el menor adulto no puede comparecer en juicio como actor sino autorizado o representado por su representante legal (padre o madre). Asimismo, en las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor dirigirse al representante para que autorice o represente al hijo en la litis. Empero, no es necesario la intervención paternal para proceder criminalmente contra el hijo. En lo que se refiere a materias extrajudiciales, los actos o contratos celebrados por el menor son nulos relativamente por falta de capacidad, a menos que hayan sido autorizados por su padre o por su curador en su caso.

Si el menor adulto no tiene padre o madre que pueda representarlo o autorizarlo, debe nombrársele un curador general de acuerdo a las reglas de los artículo 435 y siguientes del CC.

No obstante lo señalado precedentemente, el menor adulto que trabaja o ha trabajado es plenamente capaz para la mayoría de los actos y contratos que se relacionan con su empleo o profesión, o con la administración de lo que hubiere adquirido en virtud de ella. En efecto, el artículo 251 del CC señala que el menor de edad es plenamente capaz para la administración y goce de su peculio profesional, esto es, de los bienes adquiridos por el menor en el ejercicio de todo empleo, de toda profesión liberal, de toda industria, de todo oficio mecánico, etc. Pero la capacidad del menor no sólo se limita a la administración del peculio profesional, como pudiera

creerse. En realidad, desempeñando el menor una profesión o industria, es plenamente capaz para celebrar cualquier acto o contrato, pues de acuerdo a los términos del artículo 251 del CC, dichos contratos lo obligarán sólo en su peculio profesional o industria.

1.7 Nacionalidad.

Jurídicamente, la nacionalidad es el vínculo que liga a una persona a un estado determinado y que crea derechos y deberes recíprocos. El CC se limita a señalar que son chilenos los que la constitución del Estado declara tales, los demás son extranjeros, conforme a los artículos 10 y 11 de la Constitución Política de la República y al artículo 56 del CC.

Nuestras leyes no reconocen diferencia entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles reglados por el Código Civil conforme a su artículo 57. Este principio tiene muy escasas excepciones, y son las siguientes:

- i. La ley chilena sigue al chileno en país extraño en cuanto a las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia pero sólo respecto de su cónyuge y parientes *chilenos*, conforme al segundo número del artículo 15 del CC.
- ii. No pueden ser testigos de un testamento solemne otorgado en Chile, los extranjeros no domiciliados en Chile, conforme al décimo número del artículo 1012 del CC.
- iii. Sólo puede testar en el extranjero de acuerdo con las formalidades del testamento otorgado en Chile, el chileno o el extranjero que tenga domicilio en Chile, conforme al primer número del artículo 1028 del CC.
- iv. No pueden ser testigos en los matrimonios celebrados en nuestro país los extranjeros no domiciliados en Chile, ni las personas que no entiendan el idioma español, conforme al sexto número del artículo 14 de la LMC.
- v. Las leyes, especialmente, el DL No. 1.939 de 1977, por razones de seguridad nacional, reservan a los chilenos ciertos bienes raíces del territorio nacional, pero consagran algunas excepciones.
- vi. El artículo 998 del CC da cierta protección a los chilenos en la sucesión de un extranjero que se abra dentro o fuera del territorio de la República.

1.8 El Nombre.

Nombre es el conjunto de palabras que, en la vida social y jurídica, designa e individualiza a las personas. El nombre es la designación que sirve para individualizar a una persona en la vida social y jurídica.

- ➡ **El nombre de las personas está constituido por dos elementos: el pronombre, nombre propio o de pila**, que individualiza a una persona dentro del grupo familiar; **y el o los apellidos**, o nombre patronímico o de familia, que señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado.
- ➡ **El nombre propio, individual o de pila** lo determina la persona que requiere la inscripción del nacido en el Registro Civil, que por lo general es el padre o madre de éste; **el apellido, llamado también nombre patronímico o de familia, ha de ser el del padre seguido del de la madre**. Esta no es una costumbre universal; en otras partes, especialmente en Europa y en los países sajones, el patronímico está compuesto exclusivamente por el apellido del padre. El apellido de soltera de la madre sólo se usa, a veces, para una mayor singularización, como un segundo nombre entre éste y el patronímico. De esto resulta que el apellido paterno es siempre el último del nombre total, y que la costumbre nuestra de usar ambos apellidos produce la confusión de hacer creer que el apellido materno es el paterno.

Lo anterior tiene atinencia con los efectos del matrimonio en relación con el patronímico de la mujer. En otros países la mujer al casarse pierde su patronímico y pasa a tener el apellido del marido. En Chile la mujer al casarse conserva su patronímico y suele agregar el apellido del marido, precedido de la preposición “de”, es una simple costumbre desprovista de valor legal.

Pueden darse a una persona, todos los nombres propios que se quiera, y su elección, en Chile, es enteramente libre; no hay necesidad de atribuirle un nombre de santo o nombre ya en uso; es posible designar a la criatura con un nombre inventado o con cualquier otro. Sin embargo, esta libertad tiene límites. No puede imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje. Si el Oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo señalado, se opone a la inscripción de un nombre y el que lo solicita insiste en ello, el Oficial debe enviar de inmediato los antecedentes al Juez de Letras, quien resuelve en el menor plazo posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en la prohibición, conforme al artículo 31 de la Ley del Registro Civil.

1.8.1 El seudónimo.

El seudónimo es un nombre imaginario que voluntariamente adopta una persona para esconder o caracterizar su verdadera personalidad en una actividad determinada. Corrientemente el seudónimo es usado en las labores literarias. Muchas veces el renombre de la persona en la actividad en que utiliza el seudónimo hace que éste desplace al verdadero nombre y que llegue a ser conocida exclusivamente por él, por ejemplo, Gabriela Mistral.

Aunque a diferencia del nombre el seudónimo no es impuesto sino voluntario, sirve también para un proceso de identificación de la persona. El CC no reglamenta ni se refiere al seudónimo. Distinto es el caso con la Ley No. 17.336 sobre Propiedad Intelectual, pues dicha ley en la letra e de su artículo 5 denomina obra seudónima aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica; y, por su parte, el artículo 8 dice que se presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquella a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad. Por su parte, el número 5 del artículo 14 da al autor el derecho de exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima.

1.8.2 Cambio de nombre.

Al respecto, la Ley No. 17.344, de 22 de septiembre de 1970, dice en su artículo 1, que cualquiera persona puede solicitar, **por una sola vez, que se le autorice para cambiar sus nombres o apellidos**, o ambos a la vez, en los casos siguientes:

- i. Cuando uno u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente.
- ii. Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios.
- iii. En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiere sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieran impuesto al nacido, cuando fueren iguales.

En los casos en que una persona haya sido conocida durante más de cinco años, con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida de nacimiento, el titular puede solicitar que se supriman en la inscripción, en la de su matrimonio y en las de nacimiento de sus descendientes menores de edad, en su caso, el o los nombres que no hubiere usado.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la persona cuyos nombres o apellidos, o ambos, no sean de origen español, puede solicitar que se le autorice para traducirlos al idioma castellano. Puede, además, solicitar autorización para cambiarlos, si la pronunciación o escrituración es manifiestamente difícil en un medio de habla castellana.

El juez competente es el del domicilio del peticionario y la sentencia que autorice el cambio de nombres o apellidos, o de ambos a la vez, o la supresión de nombres propios, debe inscribirse en el Registro Civil, y sólo surte efectos legales una vez que se extiende la nueva inscripción. Una vez modificada la partida de nacimiento, la persona que haya cambiado su nombre o apellidos legalmente sólo puede usar, en el futuro, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre propio o apellidos, en la forma ordenada por el juez. Está penalmente sancionado el uso malicioso de los

primitivos nombres o apellidos y la utilización fraudulenta del nuevo nombre o apellido para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos.

1.9 Estado Civil.

El artículo 304 del CC **dice que estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.** La definición transcrita es criticada por su generalidad. Caben en ella muchas calidades, como la de capacidad de ejercicio, la de nacionalidad, etc. **Se puede definir el estado civil como la condición o calidad jurídica, determinada por las leyes, que dentro de la sociedad tiene la persona en orden a sus relaciones de familia y de la cual derivan para ella ciertos derechos y obligaciones. También se ha definido el estado civil como la calidad permanente que un individuo ocupa en la sociedad y derivada de sus relaciones de familia.**

1.9.1 Características del estado civil.

- i. **El estado civil es inherente a toda persona;** no se concibe una que no lo tenga.
- ii. **Es privativo de las personas naturales;** las jurídicas no lo tienen, porque ellas, por su propio carácter, son ajenas a las relaciones de familia.
- iii. **El estado civil está determinado por las leyes;** las personas no pueden adoptar el que les plazca, por ejemplo, una persona que contrae matrimonio, tiene necesariamente el estado civil de casado, aunque quisiera conservar su estado de soltero.
- iv. **El estado civil es uno e indivisible,** en cuanto a la fuente en que se origina; no se puede tener simultáneamente más de un estado civil derivado de una misma fuente. Por ejemplo, no se puede tener al mismo tiempo el estado civil de casado y el estado civil de soltero. La unidad se relaciona con una misma fuente de origen, por lo que nada obsta a que concurren más de un estado si las fuentes originarias son distintas. Por lo anterior no se contradice a la característica de la unidad cuando una persona tiene el estado civil de hijo legítimo y el estado de casado. La indivisibilidad del estado civil significa que se tiene respecto a todo el mundo; no se puede ser, verbigracia, soltero respecto de unos y casado respecto de otros.
- v. **El estado civil está regido por leyes de orden público y, por ende, no puede renunciarse, transferirse ni transmitirse.** Tampoco, por disposición legal expresa, puede ser objeto de transacción, conforme al artículo 2450 del CC. Además, no es susceptible de adquirirse por prescripción, pues sólo pueden adquirirse por prescripción las cosas que están en el comercio humano, conforme al artículo 2498 del CC. El estado civil es personalísimo, de

esto se deriva que en los actos de estado civil no se admita la representación legal sino sólo la voluntaria, conforme a los artículos 103 y 271 del CC.

- vi. **Los juicios sobre estado civil no pueden someterse a la decisión de árbitros, conforme a los artículos 230 y 357 del COT; deben necesariamente ser resueltos por los tribunales de justicia.**
- vii. **El estado civil es permanente en el sentido de que no se pierde mientras no se adquiera otro que lo sustituya**, por ejemplo, un individuo soltero no pierde esta calidad mientras no contraiga matrimonio.
- viii. **El estado civil da origen a derechos y cargas u obligaciones, es decir produce diversos efectos o consecuencias.** Tal sucede, por ejemplo, en los derechos y cargas de familia u obligaciones patrimoniales que se producen entre los padres y los hijos o entre los cónyuges, como el derecho de alimentos.

1.9.2 Fuentes del estado civil.

Las fuentes del estado civil están constituidas por hechos jurídicos, actos jurídicos y sentencias judiciales.

Entre los **hechos jurídicos** podemos señalar el nacimiento, la edad y la muerte, por ejemplo, el estado civil de viudo se origina por el hecho jurídico de la muerte de uno de los cónyuges. Entre los **actos jurídicos**, el matrimonio, el reconocimiento de hijos. Así, el estado civil de casado se origina por el acto jurídico matrimonial. Entre las sentencias, las de nulidad de matrimonio, la que declara la filiación de un hijo.

1.9.3 La familia y el parentesco.

El **parentesco o vínculo de familia puede ser por consanguinidad o afinidad.** Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados, conforme al artículo 28 del CC. Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer, conforme al artículo 31 del CC.

En el parentesco hay que distinguir entre la línea y el grado. **La línea es la serie de parientes que descienden unos de otros o de un antepasado común.** En el primer caso se llama línea recta; en el segundo, línea colateral. Según esto, padres, abuelos, hijos, nietos, son parientes en línea consanguínea recta; hermanos, tíos, sobrinos, primos, son parientes consanguíneos en línea colateral.

Se entiende por grado el número de generaciones que separan a los parientes. El padre y el hijo son parientes en primer grado; el abuelo y el nieto parientes en segundo grado. Para contar los grados en la línea colateral es necesario subir desde un pariente hasta el antepasado común, y desde él bajar hasta el otro. Así, entre tío y sobrino tenemos: desde el sobrino a su padre, un grado; a su abuelo, otro; del abuelo al tío, un nuevo grado; en total tres grados. Los parientes más cercanos por línea colateral son los hermanos, cuyo parentesco es de segundo grado de consanguinidad colateral.

La importancia del parentesco son muchas como sucede en materia sucesoria respecto de quienes son llamados a la herencia del causante, por ejemplo, el artículo 992 del CC señala que a falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive; entre estos últimos están los que en lenguaje corriente se llaman primos en segundo grado. También el parentesco puede constituir un impedimento para contraer matrimonio conforme al artículo 5 de la LMC que dispone que no podrán contraer matrimonio entre sí, primero, los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad; y, segundo, los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive.

1.9.4 Sentencias en materia de estado civil.

Entre las fuentes del estado civil se encuentran las sentencias judiciales. Para que una sentencia tenga este carácter es necesario, en primer término, que el estado civil que ella establece no aparezca como una cuestión accesoria de un problema diverso. La cuestión principal debatida debe haber sido precisamente el estado civil, conforme los artículos 272, 280 y 315 del CC.

Para que los fallos en estos juicios produzcan efecto en la materia el artículo 316 del CC exige, además, tres requisitos, que son los siguientes:

- i. Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada.
- ii. Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor.
- iii. Que no haya habido colusión en el juicio.

Estas sentencias, no obstante constituir sentencias declarativas, no valen sólo respecto de las personas que intervinieron en el juicio, sino respecto de todos, es decir, tienen efectos absolutos conforme al artículo 315 del CC. La acción que se ejerce en estos juicios, en que se reclama o pretende un estado civil, se denomina acción de reclamación de estado. Esta acción es imprescriptible por lo dispuesto en el artículo 320 del CC, que establece: “Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se

presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce”.

1.9.5 Registro Civil.

El estado civil se prueba, entre otros medios, por las respectivas partidas o inscripciones efectuadas en el Registro Civil. El Registro Civil es una repartición pública cuya misión es la de dejar constancia de los hechos que constituyen y modifican el estado civil de las personas. En el Registro Civil existen tres libros que se llevan por duplicado y se denominan, primero, de los nacimientos; segundo, de los matrimonios, y, tercero, de las defunciones, conforme a la Ley No. 4.808 sobre Registro Civil.

En esos libros se inscriben, respectivamente, los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos y contratos relativos al estado civil de las personas. Los demás actos y contratos que deben inscribirse los menciona esta ley, el Código Civil y otras diversas leyes.

Los registros están a cargo de funcionarios llamados oficiales de Registro Civil; con anterioridad a la ley de 17 de junio de 1884 esa labor estaba encomendada a los curas párrocos dentro de su respectiva parroquia.

1.10 El Domicilio.

El primer inciso del artículo 59 del CC señala que **el domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.** Por consiguiente, dos son los elementos del domicilio: **primero, uno material o físico, la residencia; y, segundo, otro subjetivo, psicológico o mental, el ánimo de permanecer en la residencia.**

Hay que distinguir tres conceptos distintos: **habitación, residencia y domicilio.** **La habitación o morada** es una relación de hecho de una persona con un lugar donde permanece y generalmente pernocta, pero puede ser accidental, ocasional o transitoria, por ejemplo, el pasajero que habita un tiempo en un hotel. **La residencia** es siempre una noción concreta. Se diferencia de la habitación en que aquí desaparece el aspecto de transitorio u ocasional. La residencia implica la idea de algo estabilizado; la permanencia física de una persona en un lugar determinado en forma permanente o habitual, lo que no significa que siempre, en todo momento, deba estar allí. La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren domicilio civil en otra parte, conforme al artículo 68 del CC. **En el domicilio**, en cambio, es la intención de la persona de tener el lugar de su residencia como asiento de su vida

social y jurídica. El caso más corriente es que residencia y domicilio coincidan. Por eso, el artículo 62 del CC dispone: “El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad”.

1.10.1 Presunciones del ánimo de permanencia.

El primer elemento del domicilio, la residencia, por ser de orden físico o material, es fácil de ser conocido. Nada cuesta percatarse del lugar en que está radicada la persona; pero no sucede lo mismo con el segundo elemento, **el ánimo de permanecer, de continuar radicado en dicho lugar, que depende de la voluntad del sujeto.** Este ánimo no puede ser conocido sino por manifestaciones externas que lo revelen o supongan. Es de dos clases: real y presunto. Animo real es el que tiene una existencia cierta y efectiva, y lo hay cuando la persona tiene la intención verdadera y positiva de permanecer en el lugar constitutivo de su domicilio, sea que lo hubiere expresado o no de una manera inequívoca. Animo presunto es el que se establece por presunciones, deducidas de hechos o circunstancias señalados por la ley. Estas presunciones son negativas o positivas. Por las primeras se concluye que no hay ánimo de permanecer en un lugar dado; lo contrario sucede con las presunciones positivas, o sea, que hay ánimo de permanecer en un lugar y, por ende, tener éste como domicilio.

Con respecto a las presunciones negativas, a ellas se refiere el artículo 63 del CC que dispone: “No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere, consiguientemente, domicilio civil en un lugar, por el sólo hecho de habitar el individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si se tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante”. También alude a las presunciones negativas el artículo 65 del CC que señala: “El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o desterrado de la misma manera fuera de la República, retendrá el domicilio anterior, mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios”.

Con respecto a las presunciones positivas, el CC Civil considera presunciones positivas al manifestar el artículo 64 que “Se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas”.

1.10.2 Clases de domicilio.

- i. El domicilio se divide en **político y civil**, conforme al segundo inciso del artículo 59 del CC.

El domicilio político es relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene o adquiere eso se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad de extranjero. La constitución y efectos del domicilio político pertenecen al Derecho Internacional, conforme al artículo 60 del CC, porque se trata de determinar el domicilio de una persona entre dos naciones distintas, a la inversa del domicilio civil, que se refiere a partes determinadas de un mismo Estado. Con relación al domicilio político, según lo tengan o no, las personas, sean chilenas o extranjeras, se dividen en domiciliadas y transeúntes conforme al artículo 58 del CC. Esta distinción tiene importancia para determinar los derechos y obligaciones que puedan afectar a unos y otros. **El domicilio civil**, que se llama también vecindad, es relativo a una parte determinada del territorio del Estado. Como la base de la división territorial de Chile es la comuna, con ésta se relaciona la idea de domicilio civil. El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad, conforme al artículo 62 del CC.

- ii. El domicilio puede ser **general o especial**

Domicilio general es el normal de una persona para todas sus relaciones jurídicas. El domicilio especial se refiere sólo a ciertas relaciones determinadas. Así el artículo 2350 del CC establece un domicilio especial para la fianza. Para los efectos procesales todo litigante deberá, en su primera gestión judicial, designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos en que funcione el tribunal respectivo, conforme al artículo 49 del CC. Pero generalmente **el domicilio especial** tiene carácter convencional. Así el establecido en un contrato se aplica a los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar.

- iii. Desde el punto de vista de su origen podemos distinguir entre **domicilio legal, convencional y real**.

El **domicilio legal** es impuesto por la ley a determinadas personas. Esto puede provenir de su situación de dependencia respecto de otras, o bien, del cargo que desempeñan. Respecto de los menores, el artículo 72 del CC establece que los que viven bajo patria potestad tendrán el domicilio paterno o materno, según el caso. El artículo 73 del CC agrega que los criados y dependientes tendrán el domicilio de la persona a quien sirven si residen en la misma casa. El domicilio legal proveniente del cargo que se desempeña está señalado en forma general en el artículo 64 del CC que presume el domicilio por el hecho de aceptarse en un lugar un cargo

concejal o un empleo fijo de los que se confieren por largo tiempo. Asimismo el artículo 66 del CC dice que los eclesiásticos obligados a una residencia determinada tienen su domicilio en ella. Cabe señalar que el inciso primero del artículo 311 del COT dispone que: “Los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios”. El **domicilio convencional** está establecido por el artículo 69 del CC que dispone: “Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato”. **Este domicilio especial**, que puede ser ficticio o llegar a serlo, es, sin embargo, unilateralmente inmutable mientras dure la convención; ello porque ha pasado a formar parte del contenido y, por lo tanto, de la ley del contrato conforme a los artículos 1545 y 1546 del CC. El domicilio convencional es limitado tanto en la materia como en el tiempo. Es limitado en la materia porque sólo se aplica a los efectos a que diere lugar el contrato; esto mismo hace que deba interpretarse y aplicarse restrictivamente. Es limitado en cuanto al tiempo, porque sólo durará mientras tenga efecto el contrato. El domicilio real, llamado también de hecho o voluntario, es la norma general y el que resulta de la definición del artículo 59 del CC.

1.10.3 Pluralidad de domicilios.

Nuestro ordenamiento jurídico, en contra de la teoría según la cual una persona no puede tener sino un domicilio, se pronuncia por la pluralidad del mismo. El artículo 67 del CC dispone: “Cuando concurren en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo”.

Corroborar la anterior disposición el artículo 140 del COT que señala: “Si el demandado tuviere su domicilio en dos o más lugares, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos”.

1.10.4 Importancia del domicilio.

El domicilio tiene gran trascendencia en el campo del derecho, conforme las siguientes consecuencias que de él se derivan:

- i. **El matrimonio debe celebrarse ante el oficial del Registro Civil** de la comuna o sección en que cualquiera de los contrayentes tenga su domicilio, o haya vivido los tres últimos meses anteriores a la fecha del matrimonio, conforme al artículo 35 de la Ley de Registro Civil.
- ii. **La sucesión en los bienes de una persona se abre en su último domicilio**, conforme al primer inciso del artículo 955 del CC.

- iii. **El juez competente para declarar la presunción de muerte es el del último domicilio** que el desaparecido haya tenido en Chile, conforme al artículo 81 del CC.
- iv. **Los artículos 1587 a 1589 del CC señalan el lugar donde debe efectuarse el pago.** Si no hay un lugar establecido convencionalmente las obligaciones de especie o cuerpo cierto se pagarán en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación, y las obligaciones de género deben pagarse en el domicilio del deudor. Por lo tanto, el domicilio sirve aquí para saber dónde debe ejercer su derecho el acreedor y dónde debe el deudor cumplir sus obligaciones.
- v. En general, es juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, **el del domicilio del demandado o interesado**, respectivamente, conforme al artículo 134 del COT.
- vi. En materia de juicios, es **necesario consignar el domicilio en los escritos de demanda y de contestación a ésta**, conforme a los artículos 254 y 309 del CPC; en la lista de testigos que presenten las partes, debe indicarse el domicilio de ellos, conforme al artículo 320 del CPC.

1.11 El Patrimonio.

Se define tradicionalmente como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona valubles en dinero. En consecuencia, en el patrimonio no sólo entran los derechos, los bienes, los créditos sino también las deudas. Cuando estas últimas, en un momento dado, son más que las relaciones activas, se dice que el patrimonio tiene un pasivo mayor que el activo.

En el patrimonio sólo entran los derechos que pueden apreciarse económicamente; los que no admiten semejante estimación quedan fuera, y por eso se llaman extrapatrimoniales. Tienen este carácter, por ejemplo, los derechos políticos, los derechos de la personalidad, derecho a la vida, derecho al honor, los derechos de familia.

El patrimonio es algo distinto de los bienes que lo integran o componen en un momento dado de su existencia. En efecto, abarca no sólo los bienes presentes de su titular, sino también los futuros, es decir, los que adquiera después. Así lo revela nítidamente la norma según la cual el acreedor puede perseguir la ejecución de su derecho sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los que la ley declara inembargables, conforme al artículo 2465 del CC. De esta manera, explican los autores, el patrimonio es un continente, una bolsa que puede estar vacía, o incluso tener un contenido negativo, como sucede cuando existen más deudas que bienes. Lo que interesa es el continente, no el contenido.

1.11.1 Utilidad del concepto de patrimonio.

El patrimonio, en razón de las funciones que desempeña, sirve para explicar varios mecanismos y figuras jurídicos, entre ellos, principalmente, los siguientes: **la sucesión hereditaria, la garantía general de los acreedores y la subrogación real.**

El patrimonio permite **comprender cabalmente cómo a la muerte de una persona todo el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles pasa unitariamente a los herederos en el estado en que se encuentre.**

El concepto de patrimonio **explica el llamado derecho de prenda general o garantía genérica de los acreedores, según la cual todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, pueden servir para que sobre ellos persiga el acreedor la ejecución de su crédito no satisfecho, conforme al artículo 2465 del CC.**

1.11.2 Teorías sobre el patrimonio.

1.11.2.1 Teoría clásica del patrimonio.

La noción de patrimonio existió ya en el derecho romano, con mayor o menor amplitud; pero sus juristas comprendieron en ella sólo los elementos activos, la totalidad de los bienes pertenecientes a un sujeto, no englobando también las deudas del mismo. El Código Civil francés, al igual que el chileno, no formula en ningún título o párrafo una teoría general sobre el patrimonio, aunque muchas normas diseminadas de uno y otro cuerpo legal se refieren a éste. Nuestro Código Civil habla, por ejemplo, *del patrimonio del desaparecido en el artículo 85, de las fuerzas y obligaciones de los patrimonios, en los artículos 1066, 1170 y 1744, de la separación de patrimonios, en los artículos 1170 y 1382, etc.*

El primero en exponer una teoría general del patrimonio fue el jurista alemán, *K. S. Zachariae*. Inspirándose en Zachariae los famosos autores franceses *Aubry y Rau* construyeron la teoría del patrimonio que ha llegado a ser clásica. De acuerdo con la teoría clásica, el patrimonio está compuesto de relaciones activas y pasivas, es decir, de derechos y obligaciones o deudas susceptibles de valoración económica. Los derechos constituyen el elemento activo, el haber del patrimonio, y las obligaciones o deudas su elemento pasivo o el debe.

En cuanto a las características del patrimonio según la teoría clásica, consideran que el patrimonio es una emanación de la personalidad, como dicen *Aubry y Rau*, o, según afirmaba su precursor *Zachariae*, es la idea de la persona misma del hombre en sus relaciones con los bienes que le pertenecen. Del principio que liga el patrimonio a la personalidad derivan las demás características

que la teoría clásica atribuye al patrimonio: **primero, toda persona, sea física o jurídica, tiene un patrimonio; segundo, el patrimonio no es transferible, aunque, sí, es transmisible por sucesión, a la muerte de su titular; tercero, sólo las personas pueden tener un patrimonio, cuarto, una misma persona no puede tener sino un patrimonio, que es uno e indivisible como la persona misma.** Esta característica se conoce con el nombre de principio de la unidad del patrimonio, y, quinto, es una universalidad jurídica o de derecho. En un sentido genérico por universalidad se entiende un conjunto de bienes que forman un todo. La tradición distingue las universalidades de hecho de las universalidades de derecho. Mientras la universalidad de hecho es un complejo de cosas, homogéneas, por ejemplo, una biblioteca, o heterogéneas, por ejemplo, un establecimiento de comercio, reunidas conjuntamente por voluntad del hombre en razón del destino, o sea, de una relación funcional, por el contrario, la universalidad de derecho consiste en un complejo orgánico, creado por la ley, de relaciones jurídicas activas y pasivas, reunidas por la pertenencia a un mismo sujeto o, siempre en su estructura unitaria, a una pluralidad de sujetos, por ejemplo, es una universalidad de derecho la sucesión de una persona muerta. Algunas de las características han sido cuestionadas.

1.11.3. Teoría objetiva; el patrimonio-fin o de afectación.

En contra de la teoría clásica del patrimonio que considera a éste como un atributo y emanación de la personalidad, surgió **la teoría objetiva del patrimonio-fin o patrimonio de afectación.** De acuerdo con ella, **el patrimonio es sólo una masa de bienes, y no se encuentra indisolublemente unido a la personalidad.** La cohesión y unidad de los elementos del patrimonio no arranca de la voluntad de la persona sino del fin o destino a que está afecto el conjunto de bienes. La afectación a determinado fin justifica la existencia y razón de ser del patrimonio. *De esta idea central surge la posibilidad de patrimonio sin titulares y la de que una sola persona pueda tener varios patrimonios.*

1.11.4 Patrimonios separados.

Se dice que hay **patrimonios separados cuando dos o más núcleos patrimoniales, mutuamente independientes entre sí, tienen por titular a un mismo sujeto.** Como ejemplo, la mujer casada en sociedad conyugal cuyo patrimonio propio lo administra el marido, pero puede tener un patrimonio reservado en virtud del artículo 150 del CC cuya administración le corresponde a ella; el hijo de familia menor adulto sometido a patria potestad tiene un patrimonio general que se lo administra el padre y puede tener un peculio profesional o industrial que se forma con los bienes adquiridos por el hijo con su trabajo y cuyo goce y administración le corresponden al menor, conforme a los artículos 243 y 246 del CC.

1.11.5 Patrimonio autónomo.

Es aquel que transitoriamente carece de sujeto, por ejemplo, la herencia yacente.

Tema 2: Personas Jurídicas.

2.1 Generalidades.

El Título XXIII del Libro I, artículos 545 a 564 del CC, no obstante su denominación “**De las personas jurídicas**”, sólo trata las personas jurídicas de derecho privado que no persiguen fines de lucro, esto es, las corporaciones y fundaciones. Hay que tener presente que lo que se dispone para las corporaciones se aplica a las fundaciones en virtud del artículo 563 del CC y artículo 30 del Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica.

El artículo 545 del CC llama **persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente**. Esta definición no precisa la esencia de las personas jurídicas; indica más bien sus atributos. La jurisprudencia las define diciendo que son ciertas colectividades jurídicamente organizadas de hombres o de bienes, que el Estado reconoce y la ley las eleva a la categoría de sujetos de derecho.

2.2 Naturaleza de las personas jurídicas.

2.2.1 Teoría de la ficción legal.

Para esta teoría el único sujeto real de derechos es el hombre; pero no puede desconocerse la necesidad de proteger eficazmente a ciertas agrupaciones de intereses colectivos en los que se concentran relaciones jurídicas. Con el fin de conciliar esta necesidad con la idea de que sólo el hombre es un sujeto real de derechos, el ordenamiento jurídico finge que a aquella agrupación de intereses colectivos corresponde una persona. Esta es, pues, una persona ficticia creada por el ordenamiento jurídico positivo para atribuirle derechos y deberes.

El Código Civil chileno se inclina por esta teoría de la ficción, pues dice que se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente, en el artículo 545 del CC.

2.2.2 Teoría organicista.

Las teorías opuestas a las de la ficción afirman que la persona jurídica es una realidad. Dentro de las teorías de la realidad, la más acogida por la doctrina es la llamada organicista que sostiene que la persona jurídica es un ente dotado de voluntad propia, de órganos propios dispuestos de modo que a ellos se asignan diversas funciones, a semejanza de lo que ocurre con las personas físicas. En síntesis, la teoría organicista concibe a la persona jurídica como un ente real, semejante a la persona física, orgánico, unitario y, como tal, dotado de vida natural.

2.2.3 Teoría normativa de Kelsen.

De acuerdo con su teoría pura del derecho, Kelsen llega a la conclusión de que **la noción de persona, para el derecho, no es una realidad o un hecho, sino una categoría jurídica, un producto del derecho y que por sí no implica necesariamente ninguna condición de corporalidad o espiritualidad en quien la recibe.** Kelsen parte de la idea que toda norma jurídica tiene un destinatario, sea un individuo o una colectividad, y todo destinatario de la norma es un sujeto de derecho y, en consecuencia, persona. La circunstancia de que la norma atribuya a alguien un derecho o un deber, constituye a ese alguien en persona, sin que importe que ese alguien sea un individuo o una colectividad. El que por lo general la norma atribuya los derechos o facultades a los seres humanos no quiere decir que el concepto jurídico de persona debe coincidir con el concepto filosófico de hombre, ente humano racional, especialmente si se considera que al mismo ser humano el derecho no lo toma en cuenta en su actuación íntegra y total, sino en el obrar jurídicamente relevante.

2.2.4 Teoría de la finalidad.

Hay teorías que suprimen sin más el sujeto, que normalmente no puede faltar, y lo sustituyen por la finalidad. Conciben **la persona jurídica como un patrimonio o conjunto de relaciones jurídicas que se mantienen unidas por su finalidad unitaria.**

2.3 Clasificaciones de las personas jurídicas.

Conforme al segundo inciso del artículo 547 del CC las personas jurídicas se clasifican en de **derecho público** y de **derecho privado**. Las **personas jurídicas de derecho privado** admiten a su vez una gran clasificación entre las que persiguen fines de lucro, y las que no tienen por objeto el lucro. Las primeras están constituidas por las **sociedades**, y las segundas por las **corporaciones y fundaciones**. Las sociedades pueden ser civiles o comerciales según se formen o no para negocios que la ley califica de actos de comercio, con excepción de la anónima que

siempre es mercantil. Las sociedades pueden ser colectivas, en comandita, anónimas y de responsabilidad limitada.

2.4 Corporaciones y Fundaciones.

El título “De las personas jurídicas” del CC se ocupa de dos tipos de entes que pueden obtener la personalidad jurídica: las corporaciones y fundaciones. **Corporación es un conjunto de individuos asociados para la realización de un fin común que no tenga carácter de lucro. Fundación es un conjunto de bienes destinado por uno o más individuos a un fin benéfico o de interés general.**

La diferencia sustancial entre las corporaciones y las fundaciones es que las primeras tienen como elemento básico o prevaleciente una colectividad de individuos; las fundaciones, un conjunto de bienes, lo que tiene una serie de consecuencias, así por ejemplo, la corporación puede disolverse si la autoridad no ejerce la facultad del artículo 560 del CC y las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes.

2.5 Constitución de las personas jurídicas.

El CC preceptúa en su artículo 546 que: “No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República”. En el segundo caso su constitución se rige por el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica, No. 110 de 1979.

La constitución es solemne, ya que los artículos 2 y 3 del Reglamento exigen escritura pública. La solicitud en que se pida la concesión de la personalidad jurídica, a la que debe acompañarse una copia autorizada de la correspondiente escritura pública, debe ser aprobada por el Presidente de la República de conformidad al artículo 23.

La fundación se constituye por la voluntad de su fundador y el Presidente de la República aprueba su existencia. Puede instituirse por un acto entre vivos o por uno mortis causa. Nuestro CC dice expresamente que cuando una asignación testamentaria tiene por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento puede solicitarse la aprobación legal, y obtenida ésta es válida la asignación, en el segundo inciso del artículo 963. En esta disposición la palabra establecimiento se refiere específicamente a la fundación.

2.5.1 Normas por las que se gobiernan las corporaciones y fundaciones.

Dichas normas son las que establecen las leyes y los estatutos. *Estatutos* es el conjunto de reglas que rigen la organización, funcionamiento y disolución o extinción de la corporación o fundación,

establecida por los miembros de la primera y por el fundador de la segunda, conforme a los artículos 548, 553 y 562 del CC. El contenido de los estatutos está regulado en los artículos 4 y 9 del Reglamento.

2.5.2 Registro de las personas jurídicas.

El Ministerio de Justicia lleva un Registro de Personas Jurídicas en que se anotan las corporaciones y fundaciones cuyos estatutos han sido aprobados, con indicación del número y fecha de dictación y publicación en el Diario Oficial del decreto de concesión de la personalidad jurídica y de otros relacionados con las vicisitudes de su existencia. Contiene también otros datos que sirven para la perfecta individualización de dichos entes, conforme al artículo 37 del Reglamento sobre Concesión de la Personalidad Jurídica.

2.5.3 Representación de las personas jurídicas en la legislación chilena.

Las corporaciones son representadas por las personas designadas al efecto por la ley, los estatutos o un acuerdo de la corporación, conforme al artículo 551 del CC. Para que los actos de los que obran por la persona jurídica afecten a ésta, necesario es que se desempeñen en el ejercicio de su cargo y dentro de sus atribuciones. Así lo expresa el artículo 552 del CC al decir que: *“Los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se les ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos límites, sólo obligan personalmente al representante”*.

El presidente del directorio de la corporación lo es también de ésta y la representa judicial y extrajudicialmente, conforme al artículo 11 del Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica.

2.5.4 Acuerdos de los socios de las corporaciones.

Los socios de una corporación expresan directamente sus voluntades en asambleas generales, que pueden ser ordinarias o extraordinarias. Los estatutos determinan el objeto de unas y otras. Las **Asambleas Generales Ordinarias** se celebran en las ocasiones y con la frecuencia señalada en los estatutos, en tanto que las extraordinarias tienen lugar cada vez que lo exigen las necesidades de la corporación, y en ellas sólo pueden tomarse acuerdos relacionados con los negocios indicados en los avisos de citación. Hay materias que sólo pueden tratarse en las asambleas de una u otra clase. La rendición de cuentas del Directorio y la elección de nuevo Directorio deben realizarse en la Asamblea General Ordinaria que al efecto destinen los estatutos. Sólo en Asamblea General Extraordinaria puede tratarse de la modificación de los estatutos y de la disolución de la corporación.

2.5.5 Voluntad de la corporación.

Ordinariamente, los estatutos señalan las reglas que deben seguirse para que se forme la voluntad de una corporación. Pero el Código Civil enuncia una regla general supletoria en el artículo 550 al

decir que: *“La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal de la corporación entera. La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación. Los estatutos de la corporación pueden prescribir modificaciones sobre los quórum señalados”.*

Para la disolución de una corporación o la modificación de sus estatutos, el quórum necesario para acordar dicha disolución o modificación es el de los dos tercios de los asistentes a la asamblea que tome la determinación, conforme al segundo inciso del artículo 18 del Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica.

2.6 Atributos de las Personas Jurídicas.

Es obvio que las personas jurídicas carecen de estado civil. Los atributos de ellas se reducen a la capacidad, el nombre, el domicilio, la nacionalidad y el patrimonio.

2.6.1 Nombre y domicilio.

Generalmente la fundación lleva el nombre de su fundador y la corporación el objeto que persigue. Respecto del domicilio tener presente el artículo 67 del CC sobre pluralidad de domicilios y el artículo 142 del COT.

2.6.2 Capacidad.

Está expresamente reconocida a la persona jurídica, pues el CC declara que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles en el artículo 545. Pero por su naturaleza propia, *esta capacidad está restringida a los derechos patrimoniales; los derechos de familia son sólo compatibles con la persona natural.*

2.6.3 La nacionalidad.

Diversos sistemas se han propuesto para determinar la nacionalidad de una corporación o fundación, y son los siguientes: **primero**, el sistema dominante considera como nacionalidad de las corporaciones y fundaciones la del país en que se constituyen y conforme a cuya legislación obtienen la personalidad jurídica; **segundo**, otro sistema da como nacionalidad de las corporaciones y fundaciones la del país en que se encuentra su sede social, y, tercero, según otros, la nacionalidad de la corporación sería la misma de las personas que controlan sus decisiones, teoría del control.

2.6.4 Patrimonio.

Las personas jurídicas, como sujetos de derecho, tienen un patrimonio, propio e independiente del de sus miembros o administradores, que les permite sufragar la actividad necesaria para alcanzar los fines que justifican su existencia. Dicha separación e independencia patrimonial la consagra

nuestro Código Civil. De acuerdo con sus disposiciones, lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; lo que pertenece a la fundación no pertenece ni en todo ni en parte al fundador, beneficiarios o administradores, conforme a los artículos 549 y 563 del CC. Por consiguiente, los bienes de la corporación son de su propiedad exclusiva, y no de todos sus miembros en conjunto o de cada uno de ellos cuotativamente. De aquí que, una vez disuelta la corporación, los asociados no tienen derecho a dividirse los bienes de ella. Recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación, conforme al artículo 549 del CC. Lo mismo rige, en cuanto a las fundaciones, respecto a sus administradores, conforme al artículo 563 del CC.

2.7 Responsabilidad de las personas jurídicas.

2.7.1 Responsabilidad penal.

La norma general en el derecho chileno es que las **personas jurídicas carecen de capacidad y responsabilidad penal, correspondiendo ésta a las personas físicas que han obrado en nombre de la jurídica**. El artículo 39 del Código de Procedimiento Penal dice: *“La acción penal, sea pública o privada, no puede dirigirse sino contra los personalmente responsables del delito o cuasidelito. La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que afecte a la corporación en cuyo nombre hubieren obrado”*. Esta misma disposición deja en claro que las personas jurídicas son susceptibles de responsabilidad civil, de indemnizar los daños que sus órganos o representantes causen cuando obran dentro de sus atribuciones.

2.7.2 Responsabilidad civil.

La responsabilidad civil extracontractual está formalmente reconocida en la citada disposición del Código de Procedimiento Penal, que se pone en el caso de que el hecho ilícito que engendra responsabilidad sea al mismo tiempo penal y civil: **en el primer carácter afecta al individuo que obró en nombre de la persona jurídica, y él irá a la cárcel si ésta es la sanción del caso, y aquella soportará la indemnización de perjuicios a que haya lugar**.

Por lo que atañe a la responsabilidad contractual, el Código Civil dispone que los actos del representante de la corporación o fundación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se les ha confiado, son actos de la corporación o fundación; en cuanto excedan de estos límites, sólo obligan personalmente al representante, conforme a los artículos 552 y 563 del CC. En el primer caso, pues, la responsabilidad es de la persona jurídica.

2.8 Extinción de las personas jurídicas.

La extinción de las personas jurídicas puede ser voluntaria o por disposición de la autoridad.

2.8.1 Extinción voluntaria.

Los asociados de la corporación o los administradores de la fundación pueden tomar la iniciativa para poner fin al ente; pero no pueden por su sola voluntad decretar la extinción de la persona jurídica, pues además de esa voluntad es necesaria la de la autoridad que legitimó su existencia.

2.8.2 Extinción por disposición de la autoridad.

Las personas jurídicas pueden extinguirse por la sola voluntad de la autoridad que legitimó su existencia, aun sin o contra la voluntad de los miembros de la corporación o de los administradores de la fundación. *Así ocurre cuando la persona jurídica llega a comprometer la seguridad o los intereses del Estado, o no corresponde al objeto de su institución. Según el Reglamento, el Presidente de la República, previo informe de las autoridades correspondientes, puede cancelar la personalidad jurídica a cualquiera corporación o fundación desde el momento que la estime contraria al orden público, a las leyes, o a las buenas costumbres, o no cumpla con los fines para que fue constituida o incurra en infracciones graves a sus estatutos*

2.8.3 Causal especial de la extinción de las fundaciones.

Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención, conforme al artículo 564 del CC.

2.8.4 Extinción de la persona jurídica por disposición de los estatutos.

Las personas jurídicas pueden también extinguirse por disponerlo sus estatutos. Así sucede cuando se realizan los eventos que ellos señalan como causa de extinción; por ejemplo, *el término previsto o el logro del objeto para que fue instituida la corporación o fundación.*

2.8.5 Destino de los bienes después de extinguida la persona jurídica.

Conforme a los artículos 561 y 563 del CC disuelta una corporación o extinguida una fundación, debe disponerse de sus propiedades en la forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos. Puede que en los estatutos nada se diga sobre el destino de los bienes después de extinguida la persona jurídica. En este caso las propiedades de la corporación o fundación pasan a dominio del Estado, con la obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la institución. Corresponde al Presidente de la República señalarlos.

2.8.6 Anotaciones en el Registro de Personas Jurídicas.

En el Registro de Personas Jurídicas que se lleva en el Ministerio de Justicia deben anotarse el número y fecha del decreto que cancela la personalidad jurídica; del que ordena o aprueba la disolución de la persona jurídica y el número y fecha del decreto que destina los bienes de la misma.